

Commentaire romand Code des obligations I

Art. 41 CO

FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, in:

Luc Thévenoz, Franz Werro

Code des obligations I

3e édition, 2021

Helbing Lichtenhahn Verlag, ISBN 978-3-7190-3164-0

Art. 41

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

¹ Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

² Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer.

[Deutsche Fassung]

A. Haftung im Allgemeinen

I. Voraussetzungen der Haftung

¹ Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.

² Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.

[versione italiana]

A. Responsabilità in generale

I. Requisiti della responsabilità

¹ Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

² Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.

PLAN

	Note
I. Généralités	1
A. Contenu	1
B. Rapport avec la responsabilité contractuelle	2
II. Conditions	6
A. Dommage	7
B. Rapport de causalité	36
C. Faute	56
D. Illicéité ou contrariété aux mœurs	71

[SEITE 409] BIBLIOGRAPHIE

Cf. bibliographie Intro. CO 41-61. ANGELOZZI, La dualité de la causalité adéquate en assurance-accidents et en responsabilité civile sous l'angle des traumatismes de la colonne cervicale et des troubles psychiques, SJ 2009 181 ss; BECK, Umwelt- und Ökoschaden – Haftung und Versicherung, REAS 2009 299; BERGER-STEINER, Der Kausalitätsbeweis, in Personen-Schaden-Forum 2009, 2009, 13

ss; BRÜGGEMEIER/COLOMBI CIACCHI, Introduction, in Brügge-meier/Colombi Ciacchi (éd.), *Fundamental Rights and Private Law in the European Union*, 2010, 1 ss; BRULHART, Les lésions bénignes du rachis cervical: les enjeux pour le responsable et l'assureur, in *Les causes du dommage*, Journée de la responsabilité civile 2006, 2007, 131 ss; CHAIX, La responsabilité de l'organisateur de voyages à la lumière de la jurisprudence genevoise relative aux art. 13 et 14 LVE, RSJ 2005, 416 ss; CHAPPUIS B., Quelques dommages dits irréparables: réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine, SJ 2010 165 ss (cité: Dommages); CHAPPUIS B., Le moment du dommage: analyse du rôle du temps dans la détermination et la réparation du dommage, 2007 (cité: Moment); CHAPPUIS B., La notion de l'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, Réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence, SJ 2000 304 ss (cité: Notion); CHAPPUIS B./WERRO, La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters, in *Mélanges Pierre Wessner*, 2011, 65 ss; CHAPPUIS C., La distinction entre illicéité et faute: n'est-il pas temps de renoncer? in *Liber Amicorum Roland Brehm*, 2012 83 ss (cité: Distinction); CHAPPUIS C., Responsabilité fondée sur la confiance: tour d'horizon, in *La responsabilité fondée sur la confiance*, Journée de la responsabilité civile 2000, 2001, 21 ss; CHAPPUIS C./WERRO, La preuve en droit de la responsabilité civile: panorama de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et questions choisies, in *La preuve dans le droit de la responsabilité civile*, 2011, 13 ss; CHAPPUIS G., L'indemnisation du préjudice découlant de la naissance d'un enfant non désiré: une simple question d'arithmétique? Quelques considérations à la lumière des solutions apportées par le droit français, REAS 2006 378 ss (cité: Naissance d'un enfant non désiré); CHAULMONTET, *Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht – Eine Grundlagenstudie*, unter Berücksichtigung von Art. 32b^{bis} USG, thèse, 2010; ETIER, *Du risque à la faute: Evolution de la responsabilité civile pour le risque du droit romain au droit commun*, thèse, 2006; FABRE-MAGNAN, *Droit des obligations*, 2: Responsabilité civile et quasi-contrats, 5^e éd., 2021; FRÉSARD-FELLAY, *Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur*, thèse, 2007; GABRIEL, *Die Widerrechtlichkeit in Art. 41 Abs. 1 OR: unter Berücksichtigung reiner Vermögensschäden*, thèse, 1987; GÄCHTER, *Adäquanz im Sozialversicherungsrecht*, *Personen-Schaden-Forum* 2016, 13 ss; GAUCH, *Die Vereinheitlichung der Delikts- und Vertragshaftung*, RDS 1997 315 ss (cité: Vereinheitlichung); GAUCH, *Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts*, recht 1996 225 ss (cité: Grundbegriffe); GAUCH/SWEET, *Deliktshaftung für reinen Vermögensschaden*, in *Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag*, 1989, 117 ss; GUYAZ, *La causalité en matière de lésions cervicales non objectivables: les enjeux pour la victime*, in *Les causes du dommage*, Journée de la responsabilité civile 2006, 2007, 81 ss; HIRSCH A., *Perte de chance et causalité*, in *Les causes du dommage*, Journée de la responsabilité civile 2006, 2007, 279 ss; HÜRZELER, *Urteil des Bundesgerichts (I. zivilrechtliche Abteilung) vom 25. Juni 2012 (4A_171/2012)*, *Keine Anwendung der sozialversicherungsrechtlichen Adäquanzkriterien im Haftpflichtrecht*, SZS 2013 86 ss; HÜRZELER/TAMM/BIAGGI, *Personenschadensrecht*, 2010; JAUN, *Haftung für Sorgfaltspflichtverletzung*, thèse, habil. 2007; KADNER GRAZIANO, *Ersatz für «Entgangene Chancen» im europäischen und im schweizerischen Recht: Überlegungen anlässlich des Entscheids des Bundesgerichts vom 13.6.2007 (BGE 133 III 462) und ein Lösungsvorschlag*, REAS 2008 61 ss (cité: Ersatz für «Entgangene Chancen»); KADNER GRAZIANO, *La perte d'une chance en droit privé européen: «tout ou rien» ou réparation partielle du dommage en cas de causalité incertaine*, in *Les causes du dommage*, Journée de la responsabilité civile 2006, 2007, 217 ss (cité: Perte d'une chance); KAHIL-WOLFF, *Atteintes non objectivables à la santé: l'ATF 136 V 279 et d'autres développements dans la jurisprudence du Tribunal fédéral*, JdT 2011 I 18 ss; LANDOLT, *Perte d'une chance – Verlorene oder vertane Chance? Anmerkungen zu BGE 133 III 462 ss und weiteren Urteilen des Bundesgerichts im Jahr 2007 (4C.234/2006, 4C.49/2007 und 4A_227/2007)*, REAS 2008 68 ss; LANDOLT, *Der Pflegeschaden*, in *Personen-Schaden-Forum* 2004, 67 ss (cité: Pflegeschaden); LOSER, *Rechtsprechung: Vertrauenshaftung und Verjährung im Schuldrecht*, BGE 134 III 390, recht 2009 211 ss (cité: recht); LOSER, *Die Vertrauenshaftung im Schweizerischen Schuldrecht (Grundlagen, Erscheinungsformen und Ausgestaltung im geltenden [Seite 410] Recht vor dem Hintergrund europäischer Rechtsentwicklung)*, 2006; MAGNIN/OVERNEY, *Responsabilité de l'Etat en cas de retard dans la planification*, DC 2019 74 ss; MANNSDORFER, *Pränatale Schädigung, Ausservertragliche Ansprüche pränatal geschädigter Personen*, thèse, 2000; MISTELI, *La responsabilité pour le dommage purement économique*, thèse, 1999; MORIN, *Les caractéristiques de la responsabilité fondée sur la confiance*, note à propos des ATF 128 III 324 et 130 III 345, JdT 2005 I 41 ss (cité: Note); MORIN, *La responsabilité fondée sur la confiance: étude critique des fondements d'une institution controversée*, thèse, 2002 (cité: Responsabilité fondée sur la confiance); MÜLLER, *Wrongful-life-Klage: erster Entscheid eines Obergerichts*, recht 2013 46 ss (cité: Wrongful-life); MÜLLER, *La responsabilité civile du médecin*, in *Quelques actions en responsabilité*, 2008, 99 ss (cité: Responsabilité du médecin); MÜLLER, *La perte d'une chance n'a pas perdu sa chance en droit suisse: commentaire de l'ATF 133 III 462*, REAS 2008 55 ss (cité: Commentaire); MÜLLER, *La perte d'une chance: étude comparative en vue de son indemnisation en droit suisse*,

notamment dans la responsabilité médicale, thèse, 2002 (cité: Perte d'une chance); PERRITAZ, L'**art. 50 al. 1 CO**: une norme qui fonde la responsabilité?, **PJA 2018 795** ss (cité: PJA); PERRITAZ, Le concours d'actions et la solidarité, thèse, 2017; PETITPIERRE, Le préjudice patrimonial et le tort moral: vers de nouvelles frontières? *in* Le préjudice: une notion en devenir, Journée de la responsabilité civile 2004, 2005, 63 ss; PROBST, Der Ersatz «immateriellen Schadens» im schweizerischen Haftpflicht- und Strassenverkehrsrecht, *in* Strassenverkehrsrechtstagung Freiburg 2010, 1 ss (cité: Schaden); PROBST, La causalité aujourd'hui, *in* Les causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, 2007, 15 ss (cité: Causalité); ROBERTO, Schadensrecht, thèse, 1997 (cité: Schadensrecht); RUMO-JUNGO, Haftpflicht und Sozialversicherung: Begriffe, Wertungen und Schadenausgleich, thèse habil., 1998; SCHAEER, Modernes Versicherungsrecht, 2007; SCHMID, Aspekte und Thesen der Arzthaftung, *in* Aktuelle Entwicklungen im Haftungsrecht, 2007, 111 ss; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2013; SCHÖBI, Der Umgang des Gesetzgebers mit Umweltschäden, DEP 2009 463 ss; STÖCKLI, Arztvertrag mit Drittschutzwirkung?, Noch einmal zur Haftung aus Sterilisationsfehlern, REAS 2007 200 ss; THÉVENOZ, La perte d'une chance et sa réparation, *in* Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2001, 2002, 237 ss; TOLOU, La forfaitisation du dommage, thèse, 2017; TORRIONE, Le préjudice d'être né, REAS 2006 388 ss; WALTER, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, *in* La responsabilité fondée sur la confiance, Journée de la responsabilité civile 2000, 2001, 147 ss; WEBER, Kausalität und Solidarität: Schadenszurechnung bei einer Mehrheit von tatsächlichen oder potenziellen Schädigern, REAS 2 (2010) 115 ss; WEBER/SCHAETZLE, Entwicklungen, *in* Personen-Schaden-Forum 2002, 102 ss; WERRO, Le point sur la partie spéciale du droit des obligations, RSJ 2021 596 ss (cité: RSJ 2021); WERRO, Le dommage: l'état d'une notion plurielle, *in* Le dommage dans tous ses états, Sans le dommage corporel ni le tort moral, Colloque du droit de la responsabilité civile 2013, 2013, 1 ss (cité: Dommage); WERRO, Le tort moral et la circulation routière: actualités et perspectives, *in* Journées du droit de la circulation routière Fribourg 2010, 1 ss (cité: Tort moral); WERRO, Le dommage ménager: notion et calcul, *in* Le préjudice corporel: bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, 2009, 1 ss (cité: Dommage ménager); WERRO, Le mandat dans la jurisprudence fédérale récente: questions choisies, *in* Il contratto di mandato nell'ordinamento giuridico, 2009, 3 ss (cité: Mandat dans la jurisprudence fédérale récente); WERRO, L'objection du comportement de substitution licite: de son utilité et de sa place, *in* Les causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, 2007, 53 ss (cité: Comportement de substitution licite); WERRO, Le préjudice: une notion dans la mouvance des conceptions, *in* Le préjudice: une notion en devenir, Journée de la responsabilité civile 2004, 2005, 125 ss (cité: Conclusions); WERRO, La fixation de l'indemnité: une synthèse, *in* Franz Werro (éd.), La fixation de l'indemnité, Colloque du droit de la responsabilité civile 2003, 2004, 201 ss (cité: Indemnité); WERRO, Contrat de voyage à forfait et ... vacances gâchées! Y a-t-il un lien entre l'indemnité due et le contrat?, *in* Tercier et al. (éd.), Gauchs Welt, Recht, Vertragsrecht und Baurecht, Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, 2004, 695 ss (cité: Contrat de voyage); WERRO, Die Sorgfaltspflichtsverletzung als Haftungsgrund nach Art. 41 OR, RDS 1997 343 ss (cité: Sorgfaltspflichtsverletzung); WERRO, Tort Liability for Pure Economic Loss: A Critique of Current Trends in Swiss Law, *in* Civil Liability for Pure Economic Loss, 1996, 181 ss (cité: Tort Liability); WERRO, La capacité de discernement et la faute, thèse, 1986 (cité: Capacité); WERRO, La preuve du défaut d'un vaccin et du lien de causalité avec le dommage, *in* Epiney/Hehemann (éd.), Annuaire suisse de droit européen, 2018, 280 ss (cité: Annuaire); **[Seite 411]** WERRO/MABILLARD, Le préjudice résultant du choc nerveux en cas d'accident de la circulation routière, *in* Journées du droit de la circulation routière Fribourg 2012, 2012, 1 ss; WESSNER, La responsabilité fondée sur la confiance: une fausse bonne idée, *in* Quelques actions en responsabilité, 2008, 39 ss (cité: Responsabilité fondée sur la confiance); WESSNER, Droit contractuel et droit délictuel: à la recherche de frontières naturelles en matière de responsabilité civile, RSA 1997 16 ss (cité: Droit contractuel et droit délictuel); WINIGER, L'illicéité en droit civil suisse, 2021; WINIGER, La notion de préjudice, perspectives européennes: la naissance et la vie non désirées, *in* Le préjudice: une notion en devenir, Journée de la responsabilité civile 2004, 2005, 76 ss (cité: Notion de préjudice); WINIGER, La gravité de la faute du responsable, *in* La fixation de l'indemnité, Colloque du droit de la responsabilité civile 2003, 2004, 15 ss (cité: Gravité de la faute); ZINGG, La réparation des vacances gâchées: vers une redéfinition du préjudice réparable au regard de la jurisprudence européenne, thèse, 2012.

I. Généralités

A. Contenu

CO 41 consacre une **clause générale de responsabilité pour faute** (comp. CCfr. 1240)¹. Il s'applique à tous les cas dans lesquels l'auteur d'un dommage ne répond pas en vertu d'une norme spéciale de responsabilité², laquelle prévoit soit une responsabilité objective simple, soit une responsabilité objective aggravée (cf. Intro. CO 41-61 N 3). Pour que CO 41 s'applique, l'auteur du manque de diligence – faute intentionnelle ou par négligence – doit avoir agi de manière illicite. Dans la conception ici défendue, le manque de diligence est en principe illicite (cf. N 87 ss); dans la conception consacrée, il ne l'est que s'il porte atteinte à un droit absolu ou s'il constitue la violation d'une norme de protection (cf. N 72 ss).

B. Rapport avec la responsabilité contractuelle

Lorsqu'il existe un rapport d'obligations ou un contrat entre le responsable et la victime, on admet en principe que l'acte illicite entraîne aussi la responsabilité pour inexécution des obligations de l'auteur du préjudice (cf. Intro. CO 97-109 N 9 ss). Dans ce cas, pour obtenir une indemnité, le lésé peut faire valoir les règles sur l'inexécution des obligations (CO 97 ss), en plus de celles sur la responsabilité délictuelle (CO 41 ss). La responsabilité pour acte illicite et la responsabilité pour inexécution d'une obligation coexistent, et la victime dispose d'un **concours** de responsabilités (cf. Intro. CO 97-109 N 13 ss)³. Par simplification, nous analyserons ici uniquement le cas dans lequel la responsabilité pour inexécution d'une obligation découle de la violation d'une obligation contractuelle et nous parlerons dès lors de responsabilité «contractuelle».

La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir **choisir le régime** qui lui est **le plus favorable** dans le cas concret⁴. Ce sera souvent le régime contractuel, surtout en raison du délai de prescription plus long de CO 127 (cep. CO128a; cf. CO 60 N 6). De l'avis général, le concours de responsabilités ne s'applique cependant qu'aux parties au contrat. Les tiers lésés par un comportement contraire au contrat et à la loi ne peuvent donc en principe déduire aucun droit du contrat auquel ils [Seite 412] n'étaient pas parties. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les proches de la victime décédée n'ont qu'une action délictuelle en réparation de leur perte de soutien⁵.

Quoi qu'il en soit de cette limite, la théorie du concours reste l'objet de **critiques**, notamment parce qu'elle sacrifie l'unité de la responsabilité civile et qu'elle étend à l'excès la notion d'obligation contractuelle⁶. A notre avis, cette théorie n'emporte pas la conviction car elle ne tient pas compte du fait que le contrat peut avoir pour objet la même diligence que celle qu'exige la loi⁷. Lorsque c'est le cas, il convient de ne pas traiter un éventuel manquement différemment, simplement parce que la victime est dans une relation contractuelle préexistante. Dans la conception ici défendue, la sanction spécifique de l'inexécution d'une obligation (CO 97) n'a de sens que lorsque le contrat modifie la diligence qu'impose la loi. Dans le cas contraire, on devrait traiter le manque de diligence de la même façon qu'en application de CO 41. L'exemple du médecin qui porte atteinte à l'intégrité physique de son patient offre une bonne illustration de ce qui précède: le médecin ne devrait pas répondre différemment du dommage causé selon qu'il agit sur la base d'un contrat ou non. Son obligation de diligence n'a pas un contenu distinct de son devoir légal, et la présomption de faute qui s'attache à l'absence d'un résultat promis (CO 97) n'a pas sa place dans la mise en œuvre de sa responsabilité (cf. N. 61 ss)⁸. Autre est la situation lorsqu'une personne s'engage (par contrat) à fournir une diligence accrue ou même un résultat (cf. N 92 ss). Tel pourrait (théoriquement) être le cas du médecin qui a promis une diligence plus élevée que celle qu'il doit en vertu de la loi⁹.

L'AP RC consacre l'abandon du concours de responsabilités pour le cas de violation positive du contrat qu'il soumet à CO 41 (AP RC 42), le régime de CO 97 ss ne régissant plus que les cas d'inexécution de la prestation promise (inexécution par suite

d'impossibilité fautive ou demeure)¹⁰. Ce rejet du concours de responsabilités n'a pas trouvé d'écho dans **CO2020**. Peut-être par manque de coordination des travaux, CO2020 prévoit deux dispositions différentes pour les responsabilités délictuelle et contractuelle et ne règle pas le rapport entre elles (cf. art. 46 et 118 CO 2020)¹¹.

II. Conditions

Pour que **CO 41** s'applique, il faut un dommage (cf. N 7 ss) et un rapport de causalité entre ce dommage et le fait générateur de responsabilité (cf. N 36 ss); à **CO 41**, ce fait consiste dans un acte fautif (cf. N 56 ss) et illicite (cf. N 71 ss) de l'auteur¹².

[Seite 413] A. Dommage

1. Notion

Le **dommage** se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué (cf. N 12)¹³. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence)¹⁴. Sous réserve d'exceptions (cf. N 21 ss), le dommage est donc en principe une diminution patrimoniale. Sont compris dans le patrimoine tous les biens d'une personne qui ont ou qui peuvent avoir une valeur économique¹⁵.

On distingue le dommage du **tort moral**, à savoir des souffrances psychiques que ressent la victime à la suite d'une atteinte à sa personnalité (cf. **CO 47** et 49). Lorsqu'on veut se référer à la fois à la notion de dommage et à celle de tort moral, on utilise souvent le terme de **préjudice**¹⁶. Certains déplaisirs font par ailleurs l'objet d'une indemnité, mais ils ne relèvent ni de **CO 47** ni de **CO 49**. Ces déplaisirs relèvent d'un dommage (immatériel) au sens de **CO 41**, en tant que «petit tort moral» (cf. N 25 s.) et non en tant que perte patrimoniale.

Dans les conceptions admises, on distingue également le dommage de l'atteinte portée à l'**intérêt d'affection**; celui-ci consiste dans l'attachement du propriétaire pour la chose endommagée. Il n'est pas d'ordre patrimonial et ne peut donc en principe faire l'objet d'une réparation¹⁷. Autre est la question de savoir si la perte d'une chose peut entraîner une indemnité pour tort moral¹⁸. Il faut pour cela que les conditions sévères de **CO 49** soient remplies (cf. **CO 49 N 3** ss).

Il convient de noter que la **doctrine** suisse contemporaine **remet en partie en cause l'approche restrictive** de la définition du dommage et du tort moral, en admettant la réparation de pertes qui ne se traduisent pas nécessairement en une diminution patrimoniale ou un tort moral classique (appréciation dite normative du dommage, cf. N 21 ss)¹⁹. Le législateur a suivi cette tendance. C'est ainsi que, quand un animal est blessé ou tué, **CO 43 I^{bis}** règle maintenant spécialement l'octroi possible d'une indemnité pour tenir compte de la valeur affective de celui-ci (cf. **CO 43 N 38** ss). Avec l'accroissement de la sensibilité écologique, se pose aussi de manière de plus en plus pressante la question de la réparation du dommage environnemental²⁰.

2. Distinctions

Dans la définition des dommages réparables, on retient les **distinctions** suivantes. 11

[Seite 414] a) Perte éprouvée et gain manqué

La **perte éprouvée** consiste dans la diminution de la fortune nette. Elle peut reposer sur une diminution de l'actif ou sur une augmentation du passif (p.ex. frais de réparation de la chose endommagée ou frais de traitement en cas de lésions corporelles)²¹. Le **gain manqué** consiste dans la non-augmentation de la fortune 12

nette. Il peut provenir d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (p.ex. interruption de la production dans une entreprise en raison de la panne d'une machine)²².

b) Dommage direct et dommage indirect

La distinction entre le dommage direct et le dommage indirect repose sur l'intensité du lien de causalité entre l'événement dommageable et le dommage en résultant²³. Le **dommage direct** est celui qui découle directement de l'atteinte (p.ex. dommage consécutif à la blessure que subit un piéton dans un accident). Le **dommage indirect** est causé par le concours de causes supplémentaires, de telle sorte qu'il n'apparaît plus que comme une conséquence éloignée du fait dommageable initial (p.ex. dommage provenant du fait que le piéton, blessé dans un accident, glisse sur le parquet de l'hôpital où il se fait soigner et se brise une jambe)²⁴. La distinction se rapporte moins au dommage qu'à la causalité: le responsable doit réparer le dommage direct comme le dommage indirect, pourvu que celui-ci soit encore en relation de causalité avec l'événement dommageable²⁵.

c) Dommage propre (ou direct) et dommage réfléchi

Le **dommage propre**, appelé aussi parfois dommage direct ou immédiat, est celui que subit personnellement la victime de l'atteinte. Le **dommage réfléchi** est celui que subit une tierce personne qui se trouve en relation avec la victime directe de l'atteinte (cf. N 73)²⁶. Seule la victime directe peut en principe obtenir réparation. Ainsi, en tant que victime indirecte, l'organisateur d'un concert, qui se voit contraint d'annuler celui-ci en raison de lésions corporelles subies par un musicien, ne peut pas obtenir de dommages-intérêts de la part de l'auteur des lésions²⁷. Par exception à cette règle, la loi prescrit la réparation du préjudice réfléchi dans deux cas: en matière d'indemnisation des tiers subissant une perte de soutien (cf. CO 45 N 9 ss) et en matière d'indemnité à titre de réparation morale (cf. CO 47 N 9)²⁸. La jurisprudence fait également une exception à la règle lorsqu'elle admet que la norme protectrice des intérêts du lésé violée protège également d'autres personnes²⁹.

[Seite 415] d) Dommage actuel et dommage futur

Le **dommage actuel** est celui qui s'est déjà produit jusqu'au jour du jugement de la dernière instance cantonale auprès de laquelle, selon le droit de procédure, de nouveaux faits peuvent encore être apportés et pris en compte (cf. CO 42 N 14)³⁰. Le **dommage futur** est celui qui est postérieur à ce jugement³¹. On notera que la loi prévoit expressément la réparation du dommage futur en cas de lésions corporelles (cf. CO 46 N 13 ss) ou de mort d'homme (cf. CO 45 N 9 ss; toutefois à partir du décès et non du jugement, cf. CO 45 N 24). Dans un cas comme dans l'autre, le dommage doit être certain³². Au besoin, le juge peut se contenter d'indices, en application de CO 42 II, s'il lui apparaît, en considération du cours ordinaire des choses, que le dommage s'est produit ou se produira³³. On doit au demeurant considérer que le dommage existe dès que le bilan du lésé montre une diminution, soit dès la naissance de la dette du lésé envers un tiers, sans égard à la question de savoir si ce dernier fera effectivement valoir sa prétention et si le lésé s'en acquittera. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que le lésé ne doit pas prouver avoir acquitté les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture d'une action pour que cette dette constitue un élément de son dommage³⁴.

e) Perte d'une chance

Le préjudice peut consister dans la perte d'une chance de réaliser un profit ou d'éviter un désavantage pécuniaire. Cette perte résulte de l'analyse de la **probabilité** qu'avait le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage³⁵. Compte tenu de l'aléa qui entoure le résultat, la perte n'a pas pour objet l'issue

favorable, mais bien la valeur de la probabilité d'obtenir cette issue. Ainsi conçue, la perte d'une chance relève de la quantification du dommage, et non de l'évaluation de la causalité³⁶. Dès lors qu'on peut retenir la causalité entre le fait générateur de responsabilité et la perte du résultat espéré, on évalue la chance réelle et sérieuse qui existait d'obtenir ce résultat³⁷. Par exemple, si un cheval de course se blesse peu avant le départ de la course, la perte de la chance s'analyse en relation avec la probabilité que ce cheval avait de gagner la course³⁸.

La théorie de la **perte d'une chance** a trouvé sa consécration dans certains droits étrangers³⁹ et la doctrine ici se prononce majoritairement pour son application en droit [Seite 416] suisse⁴⁰. Dans un arrêt récent concernant le diagnostic tardif d'une méningite, le Tribunal fédéral a toutefois refusé de qualifier la perte d'une chance de dommage réparable⁴¹. Plus précisément, il a considéré que le juge peut refuser la réparation d'une chance perdue sans commettre d'arbitraire. Il a estimé que la réception de cette notion en droit suisse est problématique, particulièrement au regard de la théorie de la différence (lien de causalité naturelle qui doit être admis ou rejeté; comparaison du patrimoine du lésé à deux moments fixes qui ne permet pas la prise en compte d'une notion évolutive telle que la chance perdue). Ces considérations n'emportent pas la conviction. On doit admettre que la perte d'une chance est un dommage réparable dans tous les cas où la chance perdue a une valeur économique et où le lien de causalité entre cette perte et l'acte générateur de responsabilité est acquis⁴². Il faut espérer que le Tribunal fédéral revoie sa position dans une affaire civile où il pourra exercer une pleine cognition. On notera aussi qu'art. 47 CO2020 admet la réparation de la perte d'une chance, dans la mesure où il définit le dommage comme «une perte patrimoniale ou une autre perte»⁴³.

f) Dommage corporel, dommage matériel et dommages purement économiques

Le **dommage corporel** est celui qui résulte d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique (p.ex. coup, inhalation d'amiante) ou psychique (p.ex. choc nerveux, cf. CO 47 N 2) de la victime⁴⁴. CO 45 et 46 en règlent le calcul⁴⁵. En cas de décès, ce dommage comprend les frais entraînés par le décès, le dommage survenu entre l'atteinte et le décès et la perte de soutien (cf. CO 45 N 1). En cas de lésions corporelles n'entraînant pas le décès de la victime directe, il comprend les pertes éprouvées (frais de traitement et autres; cf. CO 46 N 5 ss) et le gain manqué actuel et futur (cf. CO 46 N 7 ss).

Le **dommage matériel** est celui qui découle d'une atteinte portée à la substance d'une chose. La question de savoir si une atteinte à la seule fonction de la chose constitue un dommage ne trouve pas de réponse univoque⁴⁶, mais il n'y a guère de raison de principe [Seite 417] de s'y opposer⁴⁷. En cas de destruction totale, le dommage matériel comprend la valeur de remplacement de la chose. Lorsque celle-ci est sujette à dépréciation, il faut déduire de cette valeur la dépréciation que la chose avait déjà subie⁴⁸. En cas de destruction partielle, le dommage matériel comprend les frais de réparation et la dépréciation subie par la chose. Le dommage matériel comprend également le dommage supplémentaire dû au fait que la chose est hors d'usage (gain manqué ou perte éprouvée) ainsi que les autres frais en lien de causalité adéquate avec l'atteinte à la chose (sur le calcul du dommage matériel, cf. CO 42 N 12). A noter que la question de savoir si l'**atteinte portée à des données électroniques** (destruction, suppression, perte, modification, etc.) constitue un dommage matériel ou un dommage purement économique fait l'objet de controverses⁴⁹. Dans la conception ici défendue, on ne devrait pas traiter différemment les données électroniques des données sur papier. Le processus de dématérialisation ne doit pas réduire la protection du titulaire de ces données.

Le **dommage purement économique** se définit comme toute diminution du patrimoine ne résultant pas d'une atteinte aux droits absolus de la victime (cf. N 79, N 87)⁵⁰. On parle de dommage purement économique, car seul le patrimoine est

atteint⁵¹. Le droit suisse de la responsabilité civile ne protège en principe pas le patrimoine comme tel⁵². Selon le Tribunal fédéral, le dommage purement économique ne peut faire l'objet d'une réparation extracontractuelle que si l'acte dommageable viole une norme de comportement précisément destinée à protéger le patrimoine (cf. N 76 ss)⁵³. Tel est notamment le cas de CP 239, qui réprime les entraves aux services d'intérêt général⁵⁴, de la LFE, dont le but est d'éradiquer, de combattre et de surveiller les épizooties⁵⁵ et de CP 305^{bis}, qui protège le patrimoine de la victime du crime préalable au blanchiment d'argent⁵⁶. Tel ne serait en revanche pas le cas de CP 229, en matière de violation de l'art de construire, qui ne protège pas les victimes de dommages autres que ceux qui découlent d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle⁵⁷, ni de LDA 20 II, qui ne protégerait pas le patrimoine de l'auteur⁵⁸, ni des dispositions de la LBA et de CP 305^{ter}⁵⁹. Cette conception que consacre la jurisprudence n'emporte pas la conviction (cf. N 88).

g) Dommage «normatif»

La jurisprudence et la doctrine allemandes contemporaines ont en partie remis en cause la théorie de la différence et l'exigence du caractère involontaire de la diminution patrimoniale. Sous l'influence de ce courant, une partie de la doctrine suisse a, elle aussi, tenté d'élargir la définition classique du dommage en faisant valoir que le dommage n'est pas [Seite 418] une notion strictement arithmétique, mais bien plus – par définition – le reflet d'un jugement de valeur normatif⁶⁰. Le Tribunal fédéral ne s'est toutefois expressément référé au **dommage normatif** qu'en relation avec le dommage ménager (cf. N 27)⁶¹. Pour le dommage d'assistance (cf. N 27a s.), qui en est proche, il ne l'a pas fait⁶².

En application de la théorie du dommage normatif, la doctrine a proposé qu'on répare des **dépenses faites volontairement**, mais qui, par suite d'un événement involontaire, sont frustrées de leur raison d'être (prime d'assurance ou impôt pour un véhicule en réparation par suite d'un accident)⁶³. Elle a parlé dans ce cas de **dommage de frustration** (*Frustrationsschaden*). La doctrine a aussi voulu faire entrer dans la notion de dommage matériel certaines formes de désagréments exclus des limites étroites du tort moral⁶⁴. A quelques nuances cantonales près, la jurisprudence suisse n'a toutefois pas suivi. Elle reste attachée à une conception restrictive du dommage et refuse en principe la théorie du dommage normatif (cf. N 7)⁶⁵. Rien au demeurant ne devrait empêcher qu'on inclue certaines pertes immatérielles dans une notion élargie du dommage (cf. N 25 s.).

Relève aussi de la théorie du dommage normatif la question de la réparation du **dommage de commercialisation** (*Kommerzialisierungsschaden*). Ce dommage est celui qui résulte de la perte de l'usage d'une chose. L'idée est que cet usage a une valeur, qu'on peut évaluer en fonction du prix de cet usage sur le marché. En matière extracontractuelle, l'exemple par excellence est la perte de l'usage d'un véhicule suite à une atteinte à la propriété. En Allemagne, la pratique admet la compensation de cet inconvénient⁶⁶. En Suisse, à quelques exceptions cantonales près⁶⁷, les tribunaux la refusent⁶⁸. La privation de jouissance du véhicule ne donne droit à une indemnité que si elle entraîne une diminution patrimoniale effective, par exemple parce que la victime fait un usage professionnel de sa voiture et que la privation de cet usage est de nature à générer une perte de gain⁶⁹. Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de ne pas pouvoir **utiliser** temporairement certaines pièces d'une maison, en raison des fautes professionnelles d'un architecte, n'était pas un dommage réparable dont ce dernier devait répondre⁷⁰. Il a également refusé le remboursement des intérêts hypothécaires versés par l'acheteur d'une maison pendant les mois au cours desquels il n'a pu occuper celle-ci en raison du refus (temporaire) de la venderesse d'exécuter la vente⁷¹. Cette conception restrictive du dommage [Seite 419] peine à convaincre, surtout en matière contractuelle. En cette matière, rien n'empêche les parties de définir le dommage réparable⁷². En tout état de cause, il convient de distinguer le

dommage dit de commercialisation de celui qui résulte de **la moins-value mercantile** («*merkantiler Minderwert*») d'une chose qui, bien que parfaitement réparée, a une valeur moindre sur le marché (la voiture accidentée) en raison de l'endommagement qu'elle a subi. Ce dommage «mercantile» est, en principe, réparable⁷³.

A noter que la **délimitation entre dommage de frustration et dommage de commercialisation** est incertaine lorsque les dépenses volontaires s'accompagnent de la privation d'un usage ou de celle d'un plaisir⁷⁴. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé toute indemnisation (sur le plan contractuel) aux vacanciers n'ayant pas bénéficié de la vue sur la mer que leur avait promise l'offre de location, en considérant que les dépenses qui perdent après coup leur raison d'être ne constituent pas un dommage (dommage de frustration non réparable)⁷⁵. Dans un arrêt postérieur à cette décision, un tribunal cantonal a en revanche admis le remboursement des dépenses faites en vue de ses vacances par une personne qui n'avait pas pu en profiter parce que, soupçonnée d'un délit, elle avait été arrêtée peu avant son départ⁷⁶. Il a considéré que le fait de ne pas obtenir la contre-valeur des dépenses effectuées constituait un dommage réparable.

Plutôt qu'un dommage de frustration résultant de dépenses engagées inutilement, certains ont vu une perte immatérielle dans le fait de ne pas obtenir la contre-prestation attendue d'une dépense. Dans un arrêt de 2002, la CJUE a ainsi admis la réparation du **déplaisir lié à des vacances gâchées**, consacrant en quelque sorte un «petit tort moral» pour tracas et désagréments (CO 41 N 26). Il ne fait guère de doute que cette jurisprudence devrait valoir en droit suisse également, dès lors que, dans la LVF, le législateur a repris la directive européenne qui a consacré cette approche⁷⁷. Si on retient que la LVF consacre la réparation du dommage immatériel résultant de vacances ratées⁷⁸, on devrait en faire autant en application du droit commun (CO 41, 97)⁷⁹. Pour des raisons de cohérence, on ne saurait en effet justifier que celui qui souffre de vacances gâchées par suite de la mauvaise exécution d'un contrat de voyage ordinaire n'ait pas droit à une indemnité, alors qu'une personne subissant le même désagrément dans un voyage à forfait en obtiendrait la réparation. Par ailleurs, on devrait aussi admettre que la réparation du préjudice résultant de vacances gâchées ne se limite pas à la mauvaise exécution d'un [Seite 420] contrat. A notre avis, elle s'impose également en cas de faute délictuelle, lorsque la victime est empêchée de voyager, par exemple suite à un accident de la circulation⁸⁰.

De la même manière, celui qui reçoit une **prestation contractuelle défectueuse** qui n'entraîne ni dommage patrimonial, ni réduction du prix, ni droit à la réfection peut avoir droit à la compensation du déplaisir que lui cause la prestation reçue. Ce déplaisir n'est pas un dommage patrimonial, mais il peut constituer un «**petit tort moral**», au sens que nous venons de voir⁸¹. Certes, l'atteinte subie ne répond pas aux conditions de CO 49, qui exige des atteintes à la personnalité d'une certaine gravité. Il faut donc comprendre ce petit tort moral dans la notion de dommage immatériel au sens de CO 41, de la même façon que la notion de «dommage» au sens de LVF 16 comprend le dommage immatériel résultant de vacances gâchées. Selon nous, le «petit tort moral» de CO 41 désigne ainsi, de manière générale, la diminution du bien-être résultant des désagréments de la vie qui revêtent un caractère à la fois ordinaire, mais marqué, comparable à celui qui résulte de vacances gâchées. Tel pourrait être le cas du désagrément résultant pour un locataire du fait qu'il doit provisoirement se trouver un logement de remplacement particulièrement déplaisant⁸². Le petit tort moral pourrait également trouver application en cas de privation de l'usage d'une chose (cf. N 23).

La personne empêchée de s'occuper de son ménage en raison de lésions corporelles peut demander la réparation de son **dommage ménager** (cf. CO 45 N 18 et N 38 ss; CO 46 N 11 et N 28)⁸³. Celui-ci correspond à la perte générée par l'atteinte portée à la capacité de s'occuper du ménage. L'objet de l'indemnisation n'est pas la diminution

de la capacité de gain, mais celle de la capacité de travail comme telle⁸⁴. Selon la jurisprudence, le responsable doit en effet réparer le dommage ménager sans égard à la question de savoir si la perte subie se traduit par l'engagement effectif d'une aide de ménage, par des frais accrus pour une personne partiellement invalide, par une contribution supplémentaire des proches ou par une réduction de la qualité des services⁸⁵. Le lésé doit toutefois avoir effectivement effectué des tâches ménagères avant l'accident pour ce qui est du dommage actuel; il doit aussi démontrer qu'il se serait effectivement livré à des travaux ménagers à l'avenir et qu'il se trouve empêché de les accomplir du fait de l'accident. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut en effet pas tenir pour acquis que toute personne adulte accomplit des travaux ménagers; ce n'est que lorsque tel est bien le cas qu'on doit en principe retenir l'existence d'un dommage et au besoin se fonder sur les statistiques pour en calculer l'ampleur⁸⁶. Puisque le dommage ménager se répare même s'il ne se traduit pas par des dépenses accrues et qu'il ne correspond de ce fait à aucune diminution du **[Seite 421]** patrimoine, le Tribunal fédéral considère qu'il s'agit d'un dommage normatif⁸⁷. A notre avis, il n'y a là toutefois pas de véritable entorse à la théorie de la différence, compte tenu de la valeur économique qu'a le travail ménager⁸⁸. Au demeurant, l'évaluation du dommage ménager doit rester aussi concrète que possible et prendre en compte les particularités du cas d'espèce (âge de la victime, situation familiale, nombre d'enfants, lieu de domicile, etc.; sur le calcul du dommage ménager, cf. **CO 46 N 11**)⁸⁹.

En cas de lésions corporelles, la victime a droit au remboursement des frais d'assistance qu'entraîne l'atteinte qu'elle a subie (**CO 46 I**). Ces frais s'ajoutent à la perte de gain et au dommage ménager. Ils visent notamment les coûts résultant de l'engagement d'une aide qui fournit à la victime les soins nécessaires (pour une durée limitée ou non) ou du séjour dans un établissement médicalisé⁹⁰. On parle ici de **dommage d'assistance**⁹¹. Celui-ci comprend également les prestations en nature destinées à subvenir aux besoins vitaux de la victime (p.ex. l'achat d'un fauteuil roulant ou d'un lit médicalisé électrique)⁹². **27a**

Lorsque les **soins à domicile** sont le fait de proches, la victime peut aussi prétendre au remboursement des frais qui en résultent⁹³. La seule limite de l'obligation de réparer du responsable réside dans l'obligation du lésé de diminuer son dommage⁹⁴. Comme pour le dommage ménager (cf. **N 27**), le Tribunal fédéral octroie dès lors une indemnité à la victime au titre de son dommage d'assistance, indépendamment de la question de savoir si cette assistance se traduit par une diminution du patrimoine de la victime⁹⁵. **27b**

On relève encore qu'en raison de la théorie de la différence, la définition du dommage, compris comme la différence entre le patrimoine du lésé après l'événement dommageable et celui qui aurait été le sien sans la survenance de cet événement (cf. **N 7**), exclut les dépenses engagées volontairement pour **prévenir** l'apparition d'un éventuel préjudice (p.ex. les travaux visant à consolider un mur sur le point de s'écrouler)⁹⁶. AP RC 45f I permet au contraire la réparation des frais engagés par le lésé de bonne foi pour écarter une atteinte imminente⁹⁷. En règle générale, les assurances RC étendent également leur couverture aux frais de prévention destinés à écarter la menace d'un danger imminent. **28**

h) Dommage consécutif à la naissance d'un enfant non désiré

La question de savoir si les dépenses que les parents encourrent à la **naissance d'un enfant non désiré** constituent un dommage réparable⁹⁸ se pose notamment en cas de stérilisation ou d'avortement manqué. Elle se présente également en cas de diagnostic erroné sur l'état de santé de l'embryon ou du fœtus, décidant la mère à garder son enfant⁹⁹. Controversée en doctrine¹⁰⁰, cette question a fait l'objet **29**

d'un arrêt du Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a admis l'existence d'un dommage à la suite d'une stérilisation manquée¹⁰¹.

Les arguments qu'a développés le Tribunal fédéral à l'appui de sa position emportent la conviction¹⁰². Avec raison, les juges considèrent que les dépenses en question constituent un dommage au sens classique du terme et que l'acceptation de l'enfant par la mère ne saurait conférer à ces dépenses un caractère volontaire¹⁰³. Obliger la mère à avorter ou à donner son enfant en adoption serait choquant et contraire à la liberté personnelle de cette dernière¹⁰⁴. Rien ne démontre par ailleurs que le fait qu'un tiers paye les frais d'éducation d'un enfant à la place des parents soit contraire au bien de l'enfant¹⁰⁵.

A juste titre, le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'on devrait trancher dans le même sens la demande de parents d'un enfant né **handicapé**. Que l'enfant soit ou non né en bonne santé ne change en effet rien au caractère réparable de la dépense consécutive à sa naissance. Sans la faute du médecin, il ne serait pas né¹⁰⁶. Accepter l'existence d'un dommage réparable permet de reconnaître les conséquences financières, non prévues par les parents, de l'erreur médicale, tout en évitant de leur imposer de prendre une décision humainement difficile (avortement, potentiellement à un stade déjà avancé de la grossesse, ou adoption) pour ne pas encourir une perte.

Autre est la question de savoir si l'**enfant** lui-même peut agir¹⁰⁷ contre le médecin fautif en lui reprochant les frais qu'il encourra du fait de sa naissance (*wrongful life*). Le Tribunal fédéral a récemment répondu à cette question par la négative en retenant que l'enfant n'a pas un droit à ne pas naître¹⁰⁸. Cette réponse paraît [Seite 423] juste¹⁰⁹. En effet, est légitimé à agir pour son dommage patrimonial celui que la faute médicale a privé d'un choix (Cst. 10 II). Ce n'est pas le cas de l'enfant¹¹⁰.

A noter que la jurisprudence française a au contraire admis en 2000 dans la célèbre affaire Perruche la possibilité pour un enfant né handicapé d'agir contre le médecin fautif, mais seulement pour les frais résultant de son handicap¹¹¹. Pour écarter ce jugement, l'Assemblée nationale française a adopté le 10 février 2002 une loi qui a fait interdiction à un enfant né avec un handicap de réclamer une indemnisation du seul fait de sa naissance¹¹². L'Assemblée nationale a considéré que la faute, qui consiste dans le fait de ne pas avoir décelé le handicap *in utero*, n'est pas la cause de ce handicap; celui-ci est le fait de la nature préexistant à l'intervention du médecin. Le lien de causalité entre la faute du médecin et le handicap de l'enfant fait dès lors défaut.

Se pose par ailleurs la question de la **réparation du tort moral** subi par les parents d'une part, et par l'enfant, d'autre part. Dans la conception ici défendue, les parents ne devraient pas obtenir d'indemnité pour tort moral pour sanctionner les inconvénients et les souffrances morales résultant de la présence d'un enfant non désiré. Il faut en effet considérer que ces inconvénients trouvent une compensation dans la présence (non estimable) de l'enfant¹¹³. Il devrait en aller de même lorsque l'enfant ne naît pas en bonne santé, même si l'on peut comprendre la souffrance des parents de voir un enfant qu'ils ne voulaient pas, affecté d'une maladie importante. Selon le Tribunal fédéral, autre est toutefois la situation dans laquelle le médecin n'informe pas les parents des risques que leur enfant naisse avec un éventuel handicap et les prive de la possibilité d'effectuer des tests pour déceler le handicap. Dans le cas où l'enfant naît finalement avec un handicap, les parents peuvent obtenir du médecin une réparation du tort moral¹¹⁴. Pour ce qui est du tort moral de l'enfant, celui-ci ne devrait pas pouvoir se plaindre de sa naissance, quelle que soit sa santé¹¹⁵. En effet, de la même façon que [Seite 424] pour le dommage patrimonial (cf. N 32), l'enfant n'a pas un droit à ne pas naître ou à naître en bonne santé¹¹⁶.

3. Preuve du dommage

Sur les questions relatives à la **preuve du dommage**, cf. CO 42 N 1 ss.

B. Rapport de causalité

1. Généralités

La responsabilité fondée sur CO 41 suppose l'existence d'un rapport de causalité entre la faute de l'auteur et le dommage. On analyse ce rapport non seulement d'un point de vue logique ou naturel, mais également d'un point de vue normatif: le premier aspect relève de la **causalité naturelle** (cf. N 37 ss), le second, de la **causalité adéquate** (cf. N 43 ss). 36

2. Causalité naturelle

a) Notion

La **causalité naturelle**, ou rapport de cause à effet entre deux événements, consiste dans un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit¹¹⁷. Il s'agit d'une question de fait¹¹⁸. 37

b) Causalité outrepassante, dépassante et dépassée ou hypothétique

Lorsqu'après l'événement dommageable se produisent de nouveaux faits, qui auraient entraîné le même dommage si celui-ci n'était pas déjà survenu, on parle de **causalité outrepassante**. La causalité naturelle initiale ne cesse en principe pas. La cause subséquente ne peut plus avoir d'incidence ni sur la survenance ni sur l'étendue du dommage¹¹⁹. Ainsi, une personne qui endommage la propriété d'autrui ne peut pas se libérer en invoquant un fait postérieur qui aurait de toute manière détruit la chose (par exemple le fait que, quelques jours plus tard, un incendie aurait détruit l'immeuble où se trouvait la chose en question)¹²⁰. 38

Il en va de même lorsqu'un fait générateur de responsabilité a effectivement causé un dommage, alors qu'un fait antérieur aurait entraîné dans l'avenir ce même dommage¹²¹. On qualifie le comportement qui a effectivement provoqué le dommage de **cause dépassante** et le processus causal initial de **cause dépassée – ou hypothétique**¹²². Ici aussi, le défendeur doit en principe répondre de son comportement (dépassant): il ne peut pas se [Seite 425] prévaloir de la cause dommageable dépassée, même s'il est certain que celle-ci aurait produit ses effets tôt ou tard¹²³. On peut citer le cas du médecin qui, lors d'une opération, commet une faute entraînant la mort de son patient, alors que celui-ci serait de toute façon décédé d'un cancer peu de temps après l'acte fautif¹²⁴. La faute du médecin l'emporte (causalité dépassante) sur la maladie (causalité dépassée). 39

Le principe selon lequel on ne prend pas en compte la causalité dépassée ou hypothétique connaît toutefois certaines **exceptions**¹²⁵. Ainsi, on tient compte de la prédisposition constitutionnelle du lésé lorsque celle-ci est telle que, selon toute vraisemblance, le dommage subi se serait réalisé même sans l'accident (prédisposition constitutionnelle indépendante; cf. CO 44 N 35)¹²⁶. Cette exception n'en est toutefois pas véritablement une: l'acte de l'auteur qui déclenche la prédisposition est seulement la cause du dommage supplémentaire, alors que le dommage qui aurait de toute manière résulté de cette prédisposition indépendante ne relève pas de cet acte mais d'une autre cause. Il se justifie donc de tenir compte de la prédisposition indépendante lors du calcul du dommage (cf. CO 42 N 7 et CO 44 N 35). De la même façon, les frais d'inhumation à la charge du responsable ne comprennent en principe pas les frais de vêtements de deuil, dès lors qu'on peut les réutiliser (cf. CO 45 N 3)¹²⁷. A noter que si on ne peut pas prendre en compte une cause hypothétique (en particulier un état maladif antérieur) lors de l'examen de la causalité, on peut le faire lors du calcul du dommage ou de la fixation de l'indemnité (sur la prédisposition constitutionnelle liée, cf. CO 44 N 24 et N 33 ss)¹²⁸. 40

Il faut distinguer la causalité hypothétique décrite ci-dessus de la **causalité hypothétique en cas d'omission**¹²⁹. Il est vrai que, dans l'ordre naturel des choses, 41

une omission ne peut pas être la cause d'un effet, une «inaction» ne modifiant pas le cours extérieur des événements. D'un point de vue normatif toutefois, on peut considérer une omission comme la cause d'un dommage¹³⁰. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et secondement d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Lorsque ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage¹³¹. Le Tribunal fédéral considère que l'examen d'un tel lien de causalité hypothétique relève de la constatation des faits, sauf si le juge admet la causalité exclusivement sur la base de l'expérience de la vie¹³².

[Seite 426] Lorsque, en revanche, le défendeur peut faire valoir que le dommage serait survenu même s'il avait agi conformément au droit, sa responsabilité n'est pas engagée. On parle dans ce cas d'une objection fondée sur le **comportement de substitution licite**¹³³. Dès lors que le lésé a en principe la charge de la preuve de la causalité (cf. N 49), cette objection ne présente un intérêt que lorsque la causalité (naturelle) est présumée (cf. p.ex. CO 55) ou lorsqu'on dispense le lésé de l'établir, parce que les circonstances de fait permettent d'admettre sans preuve particulière la possibilité d'une relation causale¹³⁴. Il appartient alors au défendeur de prouver que la causalité fait en réalité défaut parce qu'un comportement licite de sa part n'aurait pas empêché le dommage de se produire¹³⁵. Il reste que, même lorsque le défendeur admet une omission, il appartient en principe au demandeur de rendre vraisemblable que celle-ci a causé son dommage (vraisemblance prépondérante). S'il n'y parvient pas, il ne devrait logiquement plus y avoir de place pour l'objection fondée sur le comportement de substitution licite, et le défendeur devrait échapper à sa responsabilité¹³⁶. Le Tribunal fédéral a au demeurant considéré et admis une telle objection dans l'exemple suivant: le propriétaire d'un terrain avait stipulé une promesse de vente prévoyant que la vente se conclurait dès l'octroi du permis de construire et que, si elle n'intervenait pas dans un certain délai, la promesse deviendrait caduque. Contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, le promettant a par la suite refusé de signer la demande de permis. Recherché par le bénéficiaire de la promesse, le promettant a fait valoir que, même s'il n'avait pas violé son obligation contractuelle, d'autres événements futurs auraient de toute manière empêché la délivrance du permis de construire et, partant, la vente. Le Tribunal fédéral a de ce fait admis l'absence de causalité entre son manquement et le dommage subi par le bénéficiaire de la promesse¹³⁷.

42

3. Causalité adéquate

a) Notion

La chaîne des événements qui relèvent de la causalité naturelle est potentiellement infinie. La théorie de la causalité adéquate permet de fixer une **limite juridique** à l'obligation de réparer un préjudice, quant au principe et quant à l'étendue de celle-ci¹³⁸. Selon cette théorie, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question¹³⁹. Il s'agit d'une question de droit¹⁴⁰. La preuve de la causalité adéquate incombe au lésé¹⁴¹. Pour décider si un fait constitue la [Seite 427] cause adéquate d'un dommage, le juge doit procéder à un **pronostic rétrospectif objectif**. Il doit se demander si on peut considérer le résultat constaté comme l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée¹⁴². Le juge n'a pas à se demander si l'auteur aurait

43

pu ou dû prévoir l'effet constaté: la prévisibilité (*ex ante*) ne peut jouer de rôle qu'en relation avec la faute¹⁴³.

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit notamment prendre en considération les objectifs de politique juridique poursuivis par les normes applicables au cas concret¹⁴⁴. La prise en compte de ces objectifs implique que la causalité adéquate en droit de la RC **s'apprécie autrement qu'en droit des assurances sociales**¹⁴⁵: les suites adéquates et inadéquates d'un accident ne sont pas nécessairement les mêmes dans les deux domaines¹⁴⁶. Le juge peut ainsi considérer qu'une conséquence inadéquate en droit des assurances sociales est adéquate en droit de la RC. Cette distinction tient notamment au fait que ce droit permet de prendre en considération les causes concomitantes du dommage, telle que la prédisposition constitutionnelle de la victime, dans le calcul du dommage (cf. CO 42 N 7 et CO 44 N 33 ss) ou de l'indemnité (cf. CO 44 N 36 ss). Il en va différemment en droit des assurances sociales où, une fois la causalité admise, les prestations sont dues dans les limites de la loi¹⁴⁷. En vertu de LAA 36 II, il n'est ainsi pas possible de prendre en considération l'état maladif antérieur, par une réduction appropriée des indemnités allouées, si celui-ci n'a eu aucune influence sur la capacité de gain du lésé avant l'accident¹⁴⁸. On notera au surplus que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a limité encore plus qu'avant la prise en charge des accidents dits du «coup du lapin» par les assurances sociales¹⁴⁹. Cette évolution devrait être une raison de plus pour conserver à l'appréciation de la causalité en droit de la RC son autonomie¹⁵⁰. Ce que la victime n'aura pas obtenu des assurances sociales, elle pourra tenter de l'obtenir du responsable civil¹⁵¹.

Si la jurisprudence reste fermement attachée à la causalité adéquate, la théorie qui la fonde est l'objet d'importantes **critiques en doctrine**¹⁵². Celle-ci considère notamment que les juges admettent la causalité trop facilement. La doctrine a ainsi développé des [Seite 428] critères supplémentaires pour limiter la responsabilité de l'auteur de manière raisonnable¹⁵³.

b) Facteurs interruptifs

La cause cesse d'être adéquate lorsqu'une autre cause apparaît à ce point prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan¹⁵⁴. On parle de **facteurs «interruptifs» de causalité**¹⁵⁵. Ces facteurs sont la force majeure, la faute grave ou le fait de la victime et la faute grave ou le fait d'un tiers¹⁵⁶. On notera que le cas fortuit, à la différence de la force majeure, n'interrompt pas le rapport de causalité adéquate. Il peut seulement conduire à la réduction de l'indemnité (cf. CO 43 N 33 ss).

La **force majeure** est un événement imprévisible et extraordinaire survenant avec une force irrésistible¹⁵⁷. Ce sont principalement les événements naturels qui entrent en ligne de compte (p.ex. tremblement de terre ou raz-de-marée)¹⁵⁸. La jurisprudence ne la retient que de façon très restrictive¹⁵⁹. Ne sont pas des cas de force majeure la foudre sur une ligne électrique, le gel sur la chaussée ou l'irruption d'un animal sur la route; dans ces différentes hypothèses, le caractère extraordinaire et imprévisible fait en effet défaut¹⁶⁰.

La **faute** ou le **fait de la victime** ne libère le responsable que si cette faute est si grave ou ce fait si déterminant qu'ils font apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée¹⁶¹. On peut retenir à titre d'exemple le cas de la personne suicidaire qui se jette devant un train en marche¹⁶². Le Tribunal fédéral n'admet que rarement l'interruption du lien de causalité en raison de la faute ou du fait de la victime¹⁶³. Une faute qui n'est pas suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité peut conduire à une réduction de l'indemnité (cf. CO 44 N 13)¹⁶⁴.

Selon le Tribunal fédéral, seule la victime capable de discernement peut se voir reprocher une faute grave de nature à interrompre le lien de causalité¹⁶⁵.

La **faute** ou le **fait d'un tiers** ne libère en principe pas non plus de sa responsabilité l'auteur d'un dommage. Il n'en va différemment que lorsque cette faute ou ce fait sont si importants qu'ils apparaissent comme la seule cause du dommage (cf. CO 43 N 21). Ici aussi, la jurisprudence se montre extrêmement restrictive¹⁶⁶. Contrairement à la faute de [Seite 429] la victime, la faute du tiers qui n'est pas suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité ne constitue pas un facteur de réduction de l'indemnité¹⁶⁷. Selon le Tribunal fédéral, on doit considérer le tiers comme coresponsable avec l'auteur du dommage et ce n'est qu'au stade des recours internes qu'on tiendra compte de sa faute (cf. Intro. CO 50-51 N 55 ss)¹⁶⁸. En l'absence de solidarité entre les coresponsables, cette conception ne convainc pas (cf. Intro. CO 50-51 N 75 ss)¹⁶⁹.

4. Preuve du lien de causalité

a) Généralités

La **preuve du lien de causalité** incombe à la victime¹⁷⁰. Celle-ci doit établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat. A noter que, conformément à CC 8, la **preuve des facteurs interruptifs** (cf. N 45 ss) incombe à l'auteur du dommage¹⁷¹.

La jurisprudence évite en général de se montrer trop rigoureuse dans l'exigence de la preuve de la causalité¹⁷². Elle n'exige pas toujours une preuve stricte et absolue, mais admet que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposés par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie¹⁷³. Ainsi, lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (*Beweisnot*), le degré de preuve requis pour démontrer l'existence du rapport de causalité se limite à la vraisemblance prépondérante¹⁷⁴. Une preuve absolue en matière de causalité hypothétique est exclue; en cas d'omission, par conséquent, une vraisemblance prépondérante pour un certain cours des événements suffit¹⁷⁵. Dans le domaine de la LRFP, il appartient au lésé de prouver le défaut du produit¹⁷⁶; il ne s'agit toutefois pas de prouver la cause du défaut, mais uniquement le fait que le produit ne présentait pas le degré de sécurité pouvant légitimement être attendu par le consommateur; là aussi, on devra souvent se contenter d'une vraisemblance prépondérante, notamment dans les cas où le produit défectueux a été détruit¹⁷⁷.

[Seite 430] L'AP RC part de la même conception que celle qui prévaut dans la jurisprudence actuelle en matière de preuve du lien de causalité, mais prévoit une règle supplémentaire pour le cas où le fait imputable à la personne recherchée ne peut être établi avec certitude, mais où le rôle de cette personne dans la chaîne causale apparaît suffisamment vraisemblable: dans cette situation, le tribunal peut «fixer l'étendue de la réparation d'après le degré de la vraisemblance» (AP RC 56d)¹⁷⁸. Applicable notamment en cas de causalité alternative et cumulative (cf. N 53 ss), la règle indique que la décision du juge ne doit pas forcément conduire à la solution alternative du tout ou rien, mais peut éventuellement admettre une **responsabilité partielle**¹⁷⁹.

b) Questions particulières

Il peut arriver que **plusieurs comportements** soient (potentiellement) la cause d'un même dommage, ce qui empêche d'imputer le préjudice à l'un ou à l'autre des responsables (potentiels). La doctrine distingue deux situations (cf. N 53 s.).

Dans la première situation, chaque comportement aurait pu à lui seul causer le dommage, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer quel comportement est effectivement en cause; on parle dans ce cas de **causalité alternative**¹⁸⁰. On peut citer l'exemple de deux personnes qui lancent chacune une pierre au bas d'une falaise; l'une de ces pierres cause la mort d'une personne qui s'y trouve, sans qu'on puisse déterminer quelle pierre est à l'origine du préjudice¹⁸¹. Dans ce cas, pour juger de la causalité, il faut distinguer selon que les responsables (potentiels) répondent d'une **faute commune** ou non (sur cette notion, cf. CO 50 N 4 ss). En présence d'une telle faute, la responsabilité des auteurs du dommage repose sur l'existence d'un **lien de causalité entre cette faute et le dommage**. Si ce lien est établi, tous les membres de la communauté des responsables répondent du dommage, y compris ceux dont le comportement n'a pas directement causé le préjudice (cf. Intro. CO 50-51 N 50)¹⁸². En revanche, **en l'absence de faute commune** (cf. CO 50), le lésé doit établir quel comportement est à l'origine du préjudice. S'il échoue dans cette preuve, la question se pose de savoir si, en l'absence de causalité, on doit libérer tous les responsables potentiels ou au contraire condamner ces derniers au motif que leur comportement individuel aurait pu, à lui seul, provoquer le préjudice. Dans un arrêt récent, rendu en matière pénale, le Tribunal fédéral a opté pour la première approche¹⁸³. En doctrine, les avis sont toutefois partagés¹⁸⁴. Certains auteurs proposent en outre une autre approche, plus nuancée, qui consacre un partage de responsabilité (cf. N 55)¹⁸⁵.

[Seite 431] La seconde situation est celle de la **causalité cumulative**. Elle concerne le cas où plusieurs personnes contribuent indépendamment les unes des autres à la survenance d'un même dommage, sans qu'il soit possible de déterminer la part afférente à chacune d'elles¹⁸⁶. On peut citer l'exemple de deux entreprises qui polluent, chacune de leur côté, une nappe phréatique; les déchets de chacune d'elles auraient suffi à polluer les eaux en question¹⁸⁷. Dans un tel cas, chaque entreprise peut être rendue responsable pour le tout, bien que ni l'une ni l'autre ne soit seule à l'origine du dommage¹⁸⁸. Là encore, certains auteurs de doctrine retiennent une solution plus nuancée, qui consiste en un partage de responsabilité (cf. N 55)¹⁸⁹.

Un courant doctrinal plaide en faveur d'une **forme de responsabilité partagée** en cas de causalité alternative ou cumulative¹⁹⁰. On relèvera qu'en comparaison avec ce qu'on admet aujourd'hui (cf. N 52 ss), cette solution a le mérite d'éviter que la victime n'obtienne aucune réparation parce qu'elle ne parvient pas à apporter la preuve de la causalité. Dans certains Etats américains, il y a un partage de responsabilité lorsqu'un même produit défectueux est fabriqué par plusieurs entreprises, sans qu'on sache laquelle est impliquée dans l'atteinte à la santé de la victime. Dans cette hypothèse, on retient une responsabilité fondée sur la part de marché de chaque responsable (*market-share liability*), en admettant que celle-ci détermine le degré de vraisemblance avec laquelle une entreprise peut être à l'origine du dommage¹⁹¹. Dans le même sens, l'AP RC prévoit la possibilité pour le tribunal de «fixer l'étendue de la réparation d'après le degré de vraisemblance» de la causalité (AP RC 56d II i.f.)¹⁹² et de fixer dès lors les parts de responsabilité (p.ex. 20%, 30% et 50%) au plan externe déjà.

C. Faute

1. Notion

a) Conception traditionnelle

On définit en général la **faute** comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique¹⁹³. Il peut s'agir d'une **faute intentionnelle** ou d'une **négligence**. Traditionnellement, on considère que la faute représente l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue l'aspect objectif¹⁹⁴. 56

Dans l'analyse de la **négligence**, le manquement est cependant objectivé: le responsable commet une faute lorsqu'il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient¹⁹⁵. Pour choisir la catégorie déterminante, on prend toutefois en compte des éléments subjectifs tels que la formation, les connaissances techniques particulières¹⁹⁶, l'âge ou le sexe de l'auteur¹⁹⁷. 57

[Seite 432] Se fondant sur cette approche, le Tribunal fédéral apprécie le comportement d'un enfant, pourtant capable de discernement, moins sévèrement que celui d'un adulte (cf. N 66)¹⁹⁸. C'est dans cette logique qu'un tribunal zurichois a pu (certes en 1925) juger qu'étant femme, la victime n'avait pas la capacité de maîtriser les dangers du trafic automobile et qu'on ne pouvait dès lors lui imputer sa faute concomitante¹⁹⁹! Cet exemple sans doute montre toutes les limites de cette approche subjective. On la retrouve toutefois dans l'AP RC (prise en compte de facteurs comme l'âge, la formation, les connaissances, la situation personnelle et autres aptitudes ou qualités de l'auteur; cf. AP RC 48a). CO 2020 a pris le contrepied de cette approche, à l'image de la critique qui suit²⁰⁰. 58

b) Critique

L'approche traditionnelle de la faute est critiquable, en ce qu'elle prend en compte la catégorie de personnes à laquelle appartient l'auteur du dommage pour déterminer la règle de comportement qu'il devait respecter, au besoin même les aptitudes individuelles de ce dernier. En contradiction avec le but de la RC (cf. Intro. CO 41-61 N 2), la prise en compte des aptitudes des victimes personnelles du responsable compromet l'égalité de traitement des victimes. S'il est en principe conforme au droit de subordonner la responsabilité d'une personne à sa capacité de discernement (CC 16; cf. N 64), il ne l'est pas de permettre à l'auteur d'un dommage capable de discernement de se prévaloir d'**excuses subjectives** pour échapper à sa responsabilité. Dès lors qu'il n'a pas eu un comportement objectivement raisonnable et qu'il ne peut exciper de son incapacité de discernement en se fondant sur une des causes prévues par CC 16, l'auteur d'un dommage devrait répondre de son manque objectif de diligence. Cette conception demeure toutefois contestée par tous ceux qui considèrent la faute comme un élément essentiellement subjectif²⁰¹. A noter aussi que le comportement de celui qui a des connaissances particulières ne doit pas faire l'objet d'une appréciation plus sévère. Si l'activité à laquelle se livre le défendeur est celle d'un spécialiste, elle doit s'apprécier en revanche au regard des attentes objectives qu'on peut avoir compte tenu de l'activité à laquelle il se livre. 59

Dans la logique de notre critique, il convient de distinguer deux aspects de la faute aquilienne: la **faute objective** (cf. N 61 s.) et la **faute subjective** (cf. N 63 ss). 60

La **faute objective** consiste dans le manquement à la diligence qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il s'est trouvé. Elle constitue le fondement de la responsabilité selon CO 41, mais aussi celui des responsabilités objectives simples (cf. Intro. CO 41-61 N 3). Pour décider de la diligence requise, le juge doit comparer le comportement qu'a eu l'auteur à celui qu'une personne raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances (cf. ég. N 88 s.). Pour déterminer quel était le comportement exigible de l'auteur, le juge doit tenir compte du caractère prévisible de l'événement ayant causé le dommage, de la gravité et de la probabilité de survenance du risque encouru, ainsi que de l'existence et du coût des mesures à disposition de l'auteur pour le prévenir. Il peut se référer aux dispositions de droit public édictées en vue d'assurer la sécurité. En 61

l'absence de telles règles, il peut aussi se rapporter aux [Seite 433] normes émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues. Lorsqu'il ne constate la transgression d'aucune règle de sécurité, le juge doit vérifier le respect des principes généraux de la prudence. Le cas échéant, il recherchera ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de l'auteur en procédant à une pesée des intérêts (cf. CO 56 N 16 et CO 58 N 16 ss)²⁰². Le comportement qui n'atteint pas ces exigences constitue un manque de diligence ou une faute objective²⁰³. Il appartient à la victime d'apporter la preuve de cette faute²⁰⁴.

Ainsi définie, la faute objective **ne se distingue pas de la violation positive du contrat** lorsque celui-ci a pour objet la seule diligence du débiteur (obligation de moyens, cf. N 93; comp. CO 97 N 56 ss)²⁰⁵. Du fait de l'identité entre la faute (objective) et cette violation, on ne devrait pas appliquer CO 97 quand l'obligation violée est de moyens. Dans ce cas, on ne peut pas en effet mettre à la charge du créancier la preuve de la violation du contrat et dans le même temps imposer au débiteur celle de l'absence de faute (objective) (la preuve de l'incapacité de discernement étant régie par CC 16)²⁰⁶. CO 97 ne devrait s'appliquer que lorsque l'obligation est de résultat (cf. N 94)²⁰⁷. Si le Tribunal fédéral a toujours insisté pour distinguer violation du contrat et faute quand l'obligation est de moyens, on ne connaît au demeurant aucun arrêt qui aurait retenu l'existence d'un manquement à la diligence en tant que violation du contrat, sans retenir dans le même temps également l'existence d'une faute²⁰⁸. Au demeurant, sans encore en tirer les conséquences pratiques qui en découlent, le Tribunal fédéral a reconnu dans un arrêt récent que les deux notions se recoupaient²⁰⁹.

La **faute subjective** consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne pas mettre en œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir au devoir de diligence qui lui incombe. Elle peut revêtir deux formes: l'**intention**, lorsque l'auteur utilise ses capacités et sa volonté pour agir de façon dommageable, et la **négligence**, lorsqu'il ne veut pas le résultat dommageable; ici, le manquement repose sur l'inertie «coupable» de la volonté ou de l'intellect.

La faute subjective fonde l'**imputabilité** de la faute objective (cf. N 61). Cette imputabilité dépend de la **capacité de discernement** de l'auteur: celui-ci est capable de discernement s'il possède la faculté d'agir raisonnablement – qu'il soit atteint ou non d'une cause d'altération au sens de CC 16 – ou s'il n'agit pas de manière raisonnable, mais que son état ne provient pas d'une des causes prévues par la loi²¹⁰. Si l'auteur est incapable de discernement, il ne répond pas de sa faute objective, sauf aux conditions de CO 54 (cf. CO 54 N 6 ss).

[Seite 434] La capacité de discernement est **en principe présumée** (CC 16; la règle connaît une exception notamment pour les jeunes enfants). Il appartient dès lors à celui qui prétend qu'elle fait défaut d'en apporter la preuve²¹¹. Tout le monde admet que la faculté d'agir raisonnablement est une **notion relative**, qui s'apprécie par rapport à l'acte considéré²¹². Cela signifie qu'une personne peut avoir la faculté d'agir raisonnablement pour certains actes alors qu'elle ne l'a pas pour d'autres²¹³.

La question de savoir s'il faut ou non admettre en droit suisse la **faculté restreinte** d'agir raisonnablement est en revanche controversée. Pour certains auteurs, la faculté d'agir raisonnablement existe ou n'existe pas; on ne peut pas parler de niveaux de capacité de discernement en relation avec un acte déterminé²¹⁴. D'autres auteurs admettent, à notre avis avec raison, que la capacité d'une personne, et en particulier celle d'un enfant, peut être restreinte; le Tribunal fédéral en a parfois aussi jugé ainsi²¹⁵. L'enfant répond alors dans la mesure de sa capacité. La controverse n'a toutefois que peu de portée, dans la mesure où, en pratique, tout le monde apprécie avec plus d'indulgence la faute d'un enfant ou d'un adolescent que celle d'un adulte (cf. N 58)²¹⁶. Cette indulgence ne se justifie cependant pas lorsque

l'enfant a la pleine capacité de discernement. Dans cette hypothèse, il faudrait apprécier sa faute comme celle d'un adulte²¹⁷.

Dans la **LCR**, la faute ne se conçoit à notre avis qu'en termes objectifs. Elle joue un rôle dans la mise en œuvre de la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile notamment pour le libérer de sa responsabilité (cf. **LCR 59**), pour répartir le dommage dans un accident impliquant plusieurs détenteurs (cf. **LCR 60 II**) ou pour décider du partage de la responsabilité entre plusieurs détenteurs (cf. **LCR 61**). En revanche, la faute subjective ne joue aucun rôle. Cette manière de voir trouve sa justification dans le risque spécial qui fonde le principe de la responsabilité du détenteur. Le législateur l'a d'ailleurs compris ainsi puisqu'il fait de l'incapacité de discernement un fondement de la responsabilité (cf. **LCR 61 II**)²¹⁸.

2. Degrés de la faute

Le degré de la faute n'est pas décisif pour déterminer si la responsabilité de l'auteur est engagée²¹⁹. En effet, dès que celui-ci a commis une faute objective, qu'on peut lui imputer subjectivement ou dont il doit répondre en équité (**CO 54**), la responsabilité de son auteur est en principe engagée; le degré de la faute peut, en revanche, jouer un rôle dans la fixation de l'indemnité (cf. **CO 43 N 15 ss**).

[Seite 435] La pratique distingue essentiellement entre la faute grave, la faute moyenne et la faute légère (cf. **CO 43 N 17**)²²⁰. Certains auteurs estiment qu'on devrait se contenter de la faute grave et de la faute légère (comme le fait p.ex. **LCA 14**)²²¹. Sous réserve de considérations pratiques, il n'y a cependant aucune raison de ne pas mesurer tous les degrés d'intensité de la faute²²²; il serait en revanche erroné de moduler systématiquement la réparation en fonction du degré de gravité de la faute²²³. Cette gravité joue en revanche un rôle central dans la répartition du poids de la réparation dans les rapports internes en cas de pluralité des responsables (cf. **CO 50 N 14**, **CO 51 N 28**, 33, 36).

Il y a **faute grave** lorsque le comportement est objectivement ou subjectivement inexcusable²²⁴. La faute intentionnelle est en principe toujours grave. La négligence peut toutefois l'être également; c'est le cas lorsque l'auteur viole les règles les plus élémentaires de la prudence, en négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable²²⁵. La **faute légère** se définit comme le comportement objectif ou le manquement subjectif qui, sans être acceptable, n'est pas particulièrement répréhensible²²⁶. Quant à la **faute moyenne**, elle se définit de manière négative comme une faute qui n'est ni légère ni grave²²⁷.

D. Illicéité ou contrariété aux mœurs

Selon **CO 41**, une personne ne doit réparer le dommage qu'elle a causé que si son comportement fautif est aussi **illicite** (**CO 41 I**; cf. **N 72 ss**) ou **contraire aux mœurs** (**CO 41 II**; cf. **N 98 ss**). Dans la conception ici défendue, cette condition revient à vérifier qu'aucun motif justificatif n'excuse le manque objectif de diligence (cf. **N 61**) du défendeur (cf. **N 87 ss**). Nous présenterons la conception traditionnelle (cf. **N 72 ss**), tout en montrant pourquoi celle-ci n'est pas satisfaisante (cf. **N 87 ss**).

1. Illicéité

a) Généralités

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, l'illicéité constitue, à côté du dommage et du rapport de causalité, une condition générale de la responsabilité (cf. toutefois **N 90**)²²⁸. L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs²²⁹. Cette définition consacre la **conception objective de l'illicéité** (cf. **N 74 ss**)²³⁰. Ainsi comprise, l'illicéité peut ré [Seite 436] sulter de l'atteinte à un droit absolu de la victime (illicéité de résultat; *Erfolgsunrecht*) ou de la violation d'une norme de

comportement destinée à protéger le lésé (*Schutznorm*) contre le type de dommage qu'il a subi (illicéité de comportement; *Verhaltensunrecht*)²³¹.

La conception objective s'oppose à la **conception subjective de l'illicéité**. Cette dernière repose sur l'idée que tout dommage mérite réparation, à moins que l'auteur n'ait été en droit d'agir comme il l'a fait²³². Dans cette approche, il n'est donc pas nécessaire que le dommage résulte de la violation d'un droit absolu ou d'une norme protectrice pour que la victime soit indemnisée. La doctrine majoritaire rejette cette conception²³³ et considère que le législateur ne l'a envisagée qu'à titre exceptionnel, dans des situations bien déterminées (cf. p.ex. CO 41 II, N 98 ss). Ce rejet a pour conséquence que ni les dommages purement économiques (cf. N 20 et N 75), ni le dommage réfléchi (cf. N 14), n'entraînent en principe la responsabilité de leur auteur²³⁴.

b) Conception objective de l'illicéité

La conception objective (cf. N 72) distingue l'illicéité de résultat (cf. N 75) de l'illicéité de comportement (cf. N 76). Afin de pallier les limites de cette conception restrictive, le Tribunal fédéral a toutefois recouru ici et là à d'autres formes d'illicéité (cf. N 79 ss).

L'illicéité de résultat découle de l'atteinte à un droit absolu du lésé²³⁵. Par droits absolus, on entend les droits qui s'imposent à tout le monde (*erga omnes*) et dont la protection est inconditionnelle (droits de la personnalité, droits réels, droits de la propriété intellectuelle)²³⁶. Avec l'exigence de l'atteinte à un tel droit, le patrimoine comme tel n'est pas protégé (cf. N 20); le seul fait de causer un dommage à autrui n'est pas illicite. Il en va de même de l'atteinte à un droit relatif, tel une créance²³⁷. On retrouve ici la conception du droit allemand. BGB 823 I prévoit en effet que l'obligation de réparer le dommage causé de manière négligente ou intentionnelle n'existe que si l'auteur s'en prend à l'un des biens qu'il énumère: la vie, à l'intégrité corporelle, à la liberté, à la propriété ou à un autre droit «*sonstiges Recht*») du lésé²³⁸.

L'illicéité de comportement résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger la victime contre la survenance du dommage qu'elle subit²³⁹. On trouve de telles normes protectrices dans l'ordre juridique tout entier²⁴⁰, notamment en droit consti [Seite 437] tutionnel (cf. p.ex. Cst. 29 I: déni de justice²⁴¹), en droit pénal (cf. p.ex. CP 137: appropriation illégitime; CP 146: escroquerie; CP 239: entrave aux services d'intérêt général²⁴²; CP 305^{bis}: blanchiment d'argent²⁴³), en droit administratif²⁴⁴ et en droit privé. Les normes peuvent provenir du droit fédéral ou du droit cantonal²⁴⁵. Il ne doit **pas nécessairement** s'agir de **normes de droit écrit**²⁴⁶. Les règles du droit de la concurrence (cf. p.ex. LCart, LCD) peuvent aussi jouer un rôle²⁴⁷. En revanche, selon le Tribunal fédéral, CP 229 (violation des règles de l'art de construire)²⁴⁸, CP 163 (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie) et CP 167 (avantages accordés à certains créanciers)²⁴⁹, LDA 20 II (rémunération pour l'usage privé)²⁵⁰ et, en matière de blanchiment d'argent, CP 305^{ter} et les dispositions de la LBA²⁵¹ ne protègent pas le patrimoine des individus. A noter que la question de savoir si on est en présence d'une norme protectrice ou non relève d'une

interprétation souvent difficile, pour ne pas dire hasardeuse, puisqu'elle dépendra souvent du résultat que le juge considère comme juste²⁵².

L'illicéité peut être le fait d'une action ou d'une omission. Pour qu'une **omission** soit **illicite**, il faut que l'auteur ait eu un devoir d'agir (cf. N 41); le devoir d'agir s'impose à celui qui se trouve dans une position de garant par rapport à la victime²⁵³.

Conformément à CC 8, il revient **au lésé de prouver** l'atteinte à un droit absolu ou la violation de la norme de comportement le protégeant²⁵⁴. Sur cette base, le juge appréciera le caractère illicite de l'acte ou de l'omission.

En l'absence de lésion d'un droit absolu ou de violation d'une norme protectrice, la jurisprudence a admis par le passé que la victime pouvait fonder l'illicéité sur l'**interdiction de la création d'un état de fait dangereux**(*Gefahrensatz*)²⁵⁵. Selon ce principe, la personne qui crée ou entretient un état de choses dangereux doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que ce danger n'entraîne un dommage pour autrui²⁵⁶. Le Tribunal fédéral a notamment admis que celui qui entropose des fûts de benzine vides doit [Seite 438] s'assurer qu'il a écarté tout danger d'explosion²⁵⁷. De même, il a considéré que l'exploitant d'une remontée mécanique et des pistes de ski adjacentes doit prendre les mesures de précaution qu'on peut exiger de lui pour assurer la sécurité des usagers²⁵⁸; à cet égard, il peut notamment devoir matelasser les pylônes d'un téléski et sécuriser les abords des pistes²⁵⁹. Il revient au juge de concrétiser le devoir de sécurité et de déterminer quelles sont les mesures raisonnables à prendre au regard des directives établies en la matière et des devoirs généraux de la prudence²⁶⁰.

Le **Tribunal fédéral** a toutefois affirmé que, lorsque le dommage n'est ni matériel ni corporel, le principe de l'interdiction de la création d'un état de fait dangereux ne saurait pallier l'absence d'une norme protectrice²⁶¹. Pour les dommages purement économiques, on ne peut donc pas invoquer ce principe pour fonder l'illicéité de l'acte²⁶². Après avoir posé cette règle de manière incidente, le Tribunal fédéral l'a répétée à plusieurs reprises depuis, marquant ainsi sa volonté de la considérer désormais comme établie²⁶³.

La doctrine ne s'accorde pas sur l'**utilité du Gefahrensatz**. Certains auteurs considèrent que le principe sert à établir l'illicéité dans les cas d'atteintes à des droits absolus causées par une omission, une omission ne pouvant constituer un acte illicite que s'il existe un devoir d'agir²⁶⁴. D'autres sont d'avis qu'il n'est utile que pour déterminer l'existence ou l'absence de faute²⁶⁵. En effet, celui qui crée ou laisse subsister un état de choses dangereux pour autrui, sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire, manque à la diligence requise par les circonstances²⁶⁶ et commet donc une faute²⁶⁷. Les incertitudes sur la question de savoir s'il faut traiter du principe de l'interdiction de la création d'un état de fait dangereux dans l'analyse de l'illicéité ou dans celle de la faute traduisent, à notre avis, le caractère peu convaincant de la distinction entre l'illicéité et la faute (cf. N 62 et N 87). Dans les deux cas, il s'agit d'apprécier le comportement de l'auteur et de déterminer si ce dernier a pris les mesures de diligence qui s'imposaient dans les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Cela permet d'apprécier le caractère «illicite» (cf. N 87) ou «fautif» de l'omission du responsable. On notera que le principe ne devrait en revanche pas s'appliquer dans les responsabilités objectives aggravées. La création et la réalisation d'un risque constituent certes le fondement de ces responsabilités, mais indépendamment du comportement (manque de diligence) de l'auteur du dommage.

[Seite 439] Toujours pour pallier les limites de la conception objective de l'illicéité, le Tribunal fédéral s'est parfois fondé sur la **violation du principe de la bonne foi** pour admettre une responsabilité.

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a admis la responsabilité découlant de la **culpa in contrahendo**. Cette responsabilité repose sur l'idée que la bonne foi impose des

devoirs au cours des pourparlers précontractuels (cf. CO 1 N 136 ss et Intro CO 97 N 19 ss)²⁶⁸. Ces devoirs consistent notamment dans celui de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions – ce qui impose notamment de ne pas engager ou poursuivre des négociations sans avoir l'intention de conclure le contrat²⁶⁹ et de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer ce dernier à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions déterminées. En principe, chaque partie conserve cependant le droit de rompre les pourparlers sans devoir s'en expliquer²⁷⁰.

Le Tribunal fédéral a également jugé que celui qui, intentionnellement ou à la légère, **donne des informations inexactes** ou passe sous silence des faits dont il doit reconnaître l'importance pour l'autre partie engage sa responsabilité au sens de CO 41²⁷¹. Il a par la suite sanctionné de tels faits en reconnaissant une **responsabilité sui generis** («entre contrat et délit»²⁷²), **fondée sur la confiance déçue** (cf. Intro. CO 97-109 N 22d ss)²⁷³, qui n'est ni contractuelle ni délictuelle²⁷⁴. 84

Dans l'arrêt *Swissair*, le Tribunal fédéral a mis l'accent sur le caractère strict des **conditions** de la responsabilité fondée sur la confiance²⁷⁵, qu'il a précisées par la suite dans quelques arrêts²⁷⁶. Cette responsabilité suppose que, par son comportement, le responsable ait suscité chez un tiers un espoir légitime, qu'il a ensuite déçu de manière contraire à la bonne foi²⁷⁷. L'espoir ou les attentes du tiers lésé doivent apparaître dignes de protection; des attentes vagues ou générales ne sont pas propres à justifier la confiance du tiers²⁷⁸. La responsabilité fondée sur la confiance suppose en outre une relation particulière entre l'auteur et le lésé (*Sonderverbindung*), soit un rapport spécial de confiance et de fidélité²⁷⁹. Il faut enfin que le comportement de l'auteur recherché soit propre à éveiller [Seite 440] les attentes suffisamment concrètes et déterminées du lésé et que ce dernier ait pris des dispositions qui lui sont préjudiciables²⁸⁰. 85

La question de la **nature** de la responsabilité fondée sur la confiance divise les auteurs. Certains y voient une responsabilité soumise à CO 97 ss²⁸¹, d'autres une responsabilité de nature délictuelle²⁸². Le Tribunal fédéral et d'autres auteurs la considèrent comme une responsabilité «de troisième type» qui n'est ni de nature contractuelle ni de nature délictuelle²⁸³. La question est au fond académique; l'essentiel est de savoir selon quelles modalités cette responsabilité doit être mise en œuvre, que ce soit en relation avec le fardeau de la preuve du manquement, la prescription ou la responsabilité pour les auxiliaires. On notera que le Tribunal fédéral s'est rapproché de la conception délictuelle en jugeant que les prétentions issues de la responsabilité fondée sur la confiance se prescrivent dans le délai de CO 60²⁸⁴. A notre avis, la responsabilité fondée sur la confiance est de nature délictuelle et obéit donc à CO 41 ss²⁸⁵. 86

c) Appréciation

La conception restreinte de l'illicéité consacrée par le Tribunal fédéral n'est pas satisfaisante. La **distinction** qu'il fait entre l'**illicéité de résultat** et l'**illicéité de comportement** (cf. N 75 ss) est inutile. En réalité, sauf en matière de responsabilités objectives aggravées (cf. N 90, Intro. CO 41-61 N 3), l'atteinte à un droit protégé de façon absolue ne suffit en effet jamais à fonder, à elle seule, le droit à la réparation. Il faut prendre en compte le comportement du sujet de la responsabilité; c'est ce comportement, lorsqu'il est inadéquat, qui fonde en définitive l'obligation de réparer. Si celle-ci doit être contenue dans des limites raisonnables, la conception actuelle, héritée du droit libéral allemand du XIX^e siècle, n'est toutefois plus en harmonie avec le besoin de réparation et le développement des assurances. Elle limite de manière excessive les dommages réparables, en écartant le principe de la réparation des préjudices purement économiques. Demeurent en effet sans 87

réparation des préjudices prévisibles que l'auteur aurait pu éviter en se comportant de manière raisonnable. Cette absence de réparation ne se justifie pas.

Pour apprécier l'illicéité en application de CO 41, seule devrait donc compter la question de savoir comment l'auteur du dommage s'est comporté. Dans notre approche, la responsabilité repose sur la **seule violation injustifiée du devoir de diligence imposé par les circonstances du cas d'espèce**, sans égard à la nature du dommage. L'auteur doit répondre à chaque fois qu'il a adopté un comportement déraisonnable (faute objective) sans pouvoir se prévaloir de motifs justificatifs. On doit donc considérer comme déraisonnable le comportement ou l'omission qui comprend le risque prévisible d'un dommage évitable²⁸⁶. Le caractère raisonnable du comportement de l'auteur et la diligence requise de sa part s'apprécient au regard des normes (légales ou réglementaires) de comportement, du risque prévisible, de sa probabilité et de sa gravité, ainsi que de l'existence et du coût des mesures de nature à éviter sa survenance. 88

Notre conception tient compte du fait que les biens de la victime ne sont pas protégés sans limite, mais elle évite de privilégier la protection de certains biens par rapport à d'autres. Dans cette approche, les notions de **faute objective injustifiée** et d'illicéité se rejoignent et ne constituent pas deux conditions distinctes de la responsabilité (cf. N 61)²⁸⁷. Cette manière de voir se distingue toutefois de la conception subjective de l'illicéité (cf. N 73), que le Tribunal fédéral a rejetée à plusieurs reprises²⁸⁸, mais elle retient, contrairement à cette jurisprudence, le principe de la réparation du dommage purement économique (cf. N 20). En se fondant sur le comportement de l'auteur plutôt que sur le bien atteint, on peut se passer des constructions doctrinales inventées pour pallier les limites de la conception classique de l'illicéité (cf. N 74 ss) et ainsi renforcer la sécurité juridique. 89

Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'illicéité constitue une condition générale de la responsabilité (cf. N 72) est, à notre avis, contestable, et cela pour deux raisons. Premièrement, cette condition est sans pertinence dans les responsabilités objectives aggravées (cf. Intro. CO 41-61 N 3)²⁸⁹; l'existence d'un motif justificatif ne dispense en effet pas le responsable, dans un tel cas, de l'obligation de réparer le dommage découlant de l'atteinte à un droit protégé. Secondement, si l'illicéité est bien une condition inhérente aux autres responsabilités, son contenu s'analyse en relation avec les conditions propres à chacune d'elles. Dans CO 55 par exemple, l'illicéité consiste dans le caractère déraisonnable du comportement de l'employeur d'une part, et de l'auxiliaire d'autre part (cf. CO 55 N 12 et N 17). Dans CO 58, l'illicéité réside selon nous dans l'existence d'un défaut de l'ouvrage (cf. CO 58 N 16 ss). 90

L'AP RC promeut également une nouvelle conception de l'acte illicite (AP RC 46). La première nouveauté consiste dans le fait d'y inclure la violation du principe de la bonne foi, une proposition que seule une doctrine minoritaire – ici soutenue – admet aujourd'hui. La seconde consiste dans le fait de comprendre comme un acte illicite également la violation d'un devoir contractuel (cf. N 5). Sur ce point, l'AP RC a trouvé en partie son inspiration dans la proposition du professeur Jäggi, qui a remis en cause la justification d'une responsabilité contractuelle autonome, distincte de la responsabilité délictuelle. Dans l'approche de Jäggi, le fondement des deux responsabilités est le même: celui qui cause un dommage à autrui en violation d'un devoir imposé par l'ordre juridique ou le contrat commet un acte illicite et répond selon CO 41 ss. Dans cette conception, le champ de la responsabilité contractuelle se limite ainsi à la réparation du dommage spécifique que le débiteur cause au créancier lorsque l'exécution est devenue impossible (cf. CO 97 ss) ou qu'il l'a exécutée tardivement (cf. CO 102 ss)²⁹⁰. 91

[Seite 442] Si on peut approuver la solution de l'AP RC dans son principe, celle-ci omet à notre avis de faire une distinction fondamentale selon le genre d'obligations qu'il s'agit de sanctionner²⁹¹. Selon nous, il importe de distinguer les **obligations de résultat** et les **obligations de moyens**. Dans le premier type d'obligations, le 92

débiteur s'engage à fournir un résultat, alors que, dans le second, il s'engage à fournir un effort de diligence en vue d'un résultat, mais celui-ci reste en dehors de la promesse. L'obligation n'est que de moyens lorsque l'obtention du résultat dépend en partie de circonstances sur lesquelles la volonté du débiteur n'a pas de prise, c'est-à-dire lorsque l'aléa est trop considérable.

Dans la conception ici défendue, la violation d'une **obligation de moyens** devrait relever d'un régime de responsabilité pour faute prouvée, comme à CO 41. Lorsque le débiteur s'engage par contrat à mettre en œuvre sa diligence, il ne promet en effet pas plus que ce que les devoirs généraux découlant de la loi exigent déjà de lui. Il serait dès lors juste de soumettre la violation de cette promesse, comme celle des devoirs généraux, à CO 41. Puisque le débiteur n'a pas promis de résultat, le seul fait qu'il ne le fournisse pas ne permet pas de présumer le manque de diligence du débiteur. Il revient ainsi au lésé de prouver l'absence de diligence du débiteur. Certains arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière de responsabilité d'un exploitant de téléski illustrent cette approche: lorsque le devoir de diligence imposé au débiteur par le contrat est identique à son devoir légal, le fondement de la responsabilité est la violation par le débiteur de ce devoir, lequel s'analyse de la même manière qu'on soit ou non en présence d'un contrat²⁹². De la même façon, en matière médicale, la diligence que doit le médecin ne se distingue pas, selon qu'il y a contrat ou non²⁹³. C'est cette conception que reprend CO 2020²⁹⁴.

93

Il en va différemment lorsque l'**obligation a pour objet un résultat**. Le débiteur promet dans ce cas plus que ce que le devoir légal de diligence exige de lui. S'il ne fournit pas le résultat promis, la règle est de présumer un manque de diligence. Dans ce cas, le régime de responsabilité spécifique de CO 97 trouve sa pleine justification²⁹⁵. A noter qu'il ne devrait pas en aller différemment, lorsque la victime du dommage n'est pas le partenaire contractuel du débiteur tenu d'une obligation de résultat, mais un tiers lésé lors de l'exécution. Ainsi, le peintre qui s'engage envers un bailleur à blanchir le plafond d'une chambre et qui, ce faisant, salit un tapis appartenant au locataire, devrait répondre envers ce dernier du dommage causé selon CO 97. Il se justifie en effet de considérer que la promesse du résultat bénéficie à tous ceux qui sont impliqués dans la réalisation de celui-ci, c'est-à-dire tous ceux qui sont susceptibles de subir un dommage lors de l'exécution de celui-ci.

94

d) Motifs justificatifs

On retient traditionnellement que «l'illicéité peut être levée» lorsque l'auteur peut se prévaloir d'un **motif justificatif** tel que la légitime défense ou le consentement de la victime (sur les différents motifs justificatifs, cf. CO 52; cf. ég. CC 28 II). Il revient à l'auteur du dommage d'en apporter la **preuve**²⁹⁶.

95

[Seite 443] Dans cette conception, les motifs justificatifs sont l'exercice de la puissance publique, l'exercice de la force privée (légitime défense et état de nécessité, cf. CO 52 N 4 ss, N 9 ss) et le consentement de la victime et l'exercice d'un droit (cf. CO 52 N 18 ss). Dans notre conception, on doit considérer comme motifs justificatifs toutes les circonstances qui font qu'on peut considérer comme conforme au droit un comportement qui, comme tel, serait déraisonnable (cf. N 88).

96

Les motifs justificatifs jouent un rôle dans la responsabilité aquilienne et dans les responsabilités objectives simples (cf. Intro. CO 41-61 N 3). En revanche, le sujet de la responsabilité ne peut pas se prévaloir de tels motifs dans les responsabilités objectives aggravées. Son comportement n'est en effet pas décisif dans ce cas (cf. N 90). Quelles que soient les circonstances, seule importe la réalisation du risque. Ainsi, le détenteur d'un véhicule automobile qui renverse un piéton, parce qu'il transporte de toute urgence à l'hôpital un blessé dont la vie est en danger, ne peut pas invoquer l'existence d'un état de nécessité (CO 52 II) pour ne pas devoir réparer le préjudice causé²⁹⁷.

97

2. Contrariété aux mœurs

En vertu de CO 41 II, un acte dommageable qui n'est pas illicite peut tout de même engager la responsabilité de son auteur lorsque celui-ci agit intentionnellement de façon contraire aux mœurs. Cet article permet d'étendre la responsabilité à des cas dans lesquels, bien qu'il n'y ait pas d'illicéité, le sentiment juridique exige une réparation²⁹⁸. 98

Sont **contraires aux mœurs** les actes qui, sans transgresser une norme de comportement ou violer un droit subjectif défini, heurtent tout de même le sens moral et sont incompatibles avec les bons usages de la vie en société²⁹⁹. La notion est la même qu'à CO 20 I; seules les suites de la contrariété sont différentes. CO 41 II impose le versement de dommages-intérêts, CO 20 I la nullité du contrat. La contrariété aux mœurs est une notion évolutive et il appartient au juge de la concrétiser³⁰⁰. 99

Hormis l'illicéité, à laquelle se substitue la contrariété aux mœurs, les **conditions** de CO 41 II sont les mêmes qu'à CO 41 I (dommage, rapport de causalité, faute): les notions de dommage et de lien de causalité sont les mêmes. Toutefois, en matière de faute, CO 41 II n'est applicable qu'aux actes dommageables intentionnels; le dol éventuel suffit cependant³⁰¹. 100

CO 41 II a un caractère subsidiaire par rapport à CO 41 I³⁰². Son application est **exceptionnelle** et doit se faire avec une grande réserve³⁰³. Avec le développement de l'illicéité, sa portée s'est d'ailleurs considérablement amenuisée³⁰⁴. Ainsi, celui qui incite une partie à rompre ou à violer un contrat n'agit de façon contraire aux mœurs qu'en présence de circonstances particulières, telle l'intention de nuire³⁰⁵. Tombe également sous le coup [Seite 444] de CO 41 II le comportement de celui qui fausse sensiblement le jeu de l'offre et de la demande dans des enchères et en altère le résultat³⁰⁶. 101

Fussnoten:

- 1 SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.02.
- 2 BSK-KESSLER, N 1a; WERRO, RC, N 285.
- 3 Cf. ATF 130 III 193, c. 2, JdT 2004 I 214; ATF 126 III 113, c. 2.
- 4 GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, N 2941.
- 5 ATF 123 III 204, c. 2, JdT 1999 I 9; TF, 4C.194/1999 et les réf. citées. Sur la question, cf. aussi les critiques de KELLER I, 423 ss.
- 6 WIDMER/WESSNER, 65; cf. ég. DESCHENAUX/TERCIER, § 33 n. 23 ss; GAUCH, Vereinheitlichung, 315 ss; JÄGGI, Mélanges Schönenberger, 1968, 181 ss.
- 7 WERRO, RC, N 1675 ss.
- 8 Sans en tirer les conséquences appropriées, le TF souligne lui-même que la violation par le médecin de son devoir de diligence en matière contractuelle correspond à la notion d'illicéité en matière délictuelle; cf. ATF 133 III 121, c. 3.1.
- 9 Hawkins v. McGee, 84 N.H. 114, 146 A. 641 (N.H. 1929).
- 10 WIDMER/WESSNER, 65 ss.
- 11 CO 2020-FELLMANN/MÜLLER/WERRO, 46 N 1 ss; CO 2020-MÜLLER-CHEN, 118 N 1 ss.
- 12 ATF 132 III 122, c. 4.1.
- 13 ATF 133 III 462, c. 4.4.2; ATF 132 III 321, c. 2.2.1, JdT 2006 I 447; ATF 126 III 388, c. 11a.
- 14 ATF 142 III 23, c. 4.1; ATF 132 III 186, c. 8.1; WERRO, RC, N 46 ss; ROBERTO, N 23.01 ss; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 8 N 11; CHAPPUIS B., Dommages, 179 ss.
- 15 DESCHENAUX/TERCIER, § 3 N 7; PROBST, Schaden, 6 ss; pour une analyse approfondie, cf. CHAPPUIS B., Dommages, 188 ss; cf. ég. idem, Moment, N 112 ss.
- 16 ENGEL, Traité, 473.

- 17 Cf. CHAPPUIS B., Dommages, 170 ss; WERRO, Note à l'arrêt n.p. du TC valaisan du 9.7.1997, DC 1998 53 s.; ROBERTO, N 28.02 ss.
- 18 Cf. ATF 87 II 290, c. 4; DESCHENAUX/TERCIER, § 2 N 16; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 8 N 46 s.; WERRO, Dommage, 5.
- 19 Cf. ROBERTO, N 25.02 ss; PROBST, Schaden, 27 ss; WERRO, Dommage, 9 et les réf. citées.
- 20 A ce sujet, cf. WERRO, RC, N 113 ss et les réf. citées.
- 21 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 42 s.; PETITPIERRE, 65.
- 22 ATF 116 II 441, c. 3a/aa, JdT 1991 I 166; une amende ne saurait constituer une perte éprouvée: cf. ATF 115 II 75; ég. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.13; BSK-KESSLER, N 6.
- 23 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 44; CHK-MÜLLER, N 20.
- 24 ATF 133 III 257, c. 2, SJ 2007 I 461; sur cet arrêt, cf. WERRO, La vente dans la jurisprudence récente, in La pratique contractuelle: actualité et perspectives, 2009, 1 ss, 5 ss.
- 25 ATF 118 II 176, c. 4c, JdT 1994 I 554; REY/WILDHABER, N 371 ss; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.22; BK-BREHM, N 17 ss; CHK-MÜLLER, N 26.
- 26 ATF 112 II 118, c. 5e; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 48 ss; CHK-MÜLLER, N 26; WERRO/MABILLARD, 7 s.
- 27 SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.19 s.; pour un autre exemple tiré de la jurisprudence, cf. ATF 104 II 95, JdT 1978 I 557.
- 28 ENGEL, Traité, 477.
- 29 Le TF a notamment admis cette protection en application de CP 239 dans l'ATF 102 II 85 (cf. N 20); dans le c. 6c de cet arrêt, il a précisé que la question de savoir si on a affaire à un lésé direct ou indirect se recouvre avec celle de l'illicéité de l'acte incriminé.
- 30 WERRO, RC, N 153.
- 31 DESCHENAUX/TERCIER, § 23 N 14 ss.
- 32 La preuve de la certitude peut se révéler difficile; cf. ATF 129 III 18, c. 2.4, dans lequel le TF estime que la production d'un simple devis relatif aux coûts prévisibles d'assainissement d'un local contaminé à l'amiante est impropre à démontrer l'existence d'un dommage actuel.
- 33 WERRO, RC, N 155.
- 34 TF, 2P.165/2005, c. 6.3; CHAPPUIS B., Moment, N 227; PROBST, Schaden, 21 s.
- 35 ATF 133 III 462, c. 4.2; MÜLLER, Perte d'une chance, N 32; THÉVENOZ, 241. Pour une analyse synthétique, cf. WERRO, Mandat dans la jurisprudence fédérale récente, 14 s.; CHAPPUIS C./WERRO, 14 ss; MÜLLER, Responsabilité du médecin, 123 ss; CHAPPUIS B., Dommages, 169 ss.
- 36 CJ (GE), ACJC/936/2009, c. 5.2.1 (3.9.2009); BK-BREHM, CO 42 N 56a; WERRO, Dommage, 14 s.
- 37 MÜLLER, Perte d'une chance, N 32 ss; THÉVENOZ, 241; BK-BREHM, CO 42 N 56a; WERRO, RC, N 157. Pour un aperçu de la situation en droit européen, cf. KADNER GRAZIANO, Ersatz für «Entgangene Chancen», 61 ss; idem, Perte d'une chance, 217 ss.
- 38 MÜLLER, Perte d'une chance, N 32 s.
- 39 On admet la compensation de la perte d'une chance en droit français et dans certains droits américains. Pour une présentation des droits étrangers, cf. MÜLLER, Perte d'une chance, N 38 ss; THÉVENOZ, 243 ss. Les Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international reconnaissent aussi explicitement la perte d'une chance à l'art. 7.4.3 al. 2: «La perte d'une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de sa réalisation».
- 40 Cf. SCHMID, 123; ROBERTO, N 29.92 ss; BK-BREHM, CO 42 N 56a; THÉVENOZ, 243 ss; KADNER GRAZIANO, Ersatz für «entgangene Chancen», 61 ss. En faveur de la théorie de la causalité partielle, cf. HIRSCH A., 285 ss; WIDMER/WESSNER, 244. Plus critiques sur la réception de cette notion en droit suisse, HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 43; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.12a.
- 41 ATF 133 III 462, c. 4.4, confirmé à de nombreuses reprises (cf. TF, 4A_18/2015, c. 4.1-4.2; TF, 4A_91/2014, c. 6.3.3 ou encore TF, 4A_227/2007, c. 3.5.3) et commenté in MÜLLER, Commentaire, 55 ss et LANDOLT, 68 ss.

- 42 WERRO, Dommage, 14; *idem*, Mandat dans la jurisprudence fédérale récente, 14. Cf. ég. l'arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève du 3 septembre 2009 dans la cause C/8150/2007, dans lequel le demandeur a fait valoir la perte d'une chance de gagner son procès en raison de la faute de son avocat; la demande a été rejetée, non parce que la théorie de la perte d'une chance n'emporte pas la conviction, mais parce que la chance n'était en l'occurrence pas suffisamment sérieuse. Cf. ég. TOLOU, N 722 ss, qui soutient que les parties peuvent indemniser la perte d'une chance dans une clause forfaitaire.
- 43 CO 2020-FELLMANN/MÜLLER/WERRO, 47 N 2.
- 44 WERRO, RC, N 68; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.08; KELLER I, 64 et 66.
- 45 BK-BREHM, N 76.
- 46 A ce sujet, cf. ROBERTO, 05.57 et 24.05; pour des approfondissements, *idem*, Schadensrecht, 24 ss et les réf. citées.
- 47 TF, 4A_61/2015, c. 3.3 (en matière contractuelle); cf. ég. ATF 118 II 176, JdT 1994 I 554. La réparation se heurtera souvent aux limites de la couverture d'assurance.
- 48 TF, 4C.343/2001, c. 2b; cf. ég. CHAPPUIS B., Moment, N 496 ss.
- 49 En faveur d'un dommage matériel, cf. BK-BREHM, N 78c; FELLMANN/KOTTMANN, N 232; en faveur d'un dommage purement économique, cf. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 N 18.
- 50 ATF 133 III 323, c. 5.1; REY/WILDHABER, N 391 ss.
- 51 WERRO, RC, N 110; KELLER I, 66.
- 52 Pour une critique, cf. WERRO, RC, N 112.
- 53 Cf. TF, SJ 2001 I 525, c. 3.
- 54 ATF 102 II 85.
- 55 ATF 126 II 63, c. 3a.
- 56 ATF 129 IV 322, c. 2; cf. ég. CHAPPUIS B., Notion, 313.
- 57 Cf. ATF 119 II 127, JdT 1994 I 298; ég. ATF 117 II 259, JdT 1992 I 559.
- 58 ATF 134 III 214, c. 2.1, JdT 2008 I 383.
- 59 ATF 134 III 529, c. 4.3, JdT 2009 I 42; CHAPPUIS B., Notion, 304 ss.
- 60 Cf. p.ex. ROBERTO, N 25.02 s.; PROBST, Schaden, 27 ss; WERRO, Conclusions, 127; *idem*, Dommage, 9; CHAPPUIS B., Moment, N 137 ss; *idem*, Dommages irréparables, 181 ss.
- 61 Le TF a utilisé la notion de «dommage normatif» pour la première fois dans l'arrêt TF, Pra 1995 549, JdT 1996 I 728, c. 5. Depuis lors, il a utilisé cette notion à plusieurs reprises, cf. ATF 134 III 534, c. 3.2.3.1; ATF 132 III 321, c. 3.1, JdT 2006 I 447; ATF 127 III 403, c. 4b, SJ 2001 I 605; CHAPPUIS B., Moment, N 133 ss; FELLMANN/KOTTMANN, N 99.
- 62 TF, 4A_500/2009, c. 2.1, 2.4 et 3.2. A ce sujet, cf. FELLMANN/KOTTMANN, N 102 s.; MÜLLER, RC, N 87; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, N 26.
- 63 BK-BREHM, N 84b; BSK-KESSLER, N 4; ROBERTO, N 24.16 ss; WERRO, RC, N 61.
- 64 REY/WILDHABER, N 193 ss; d'un autre avis, cf. ROBERTO, N 24.01 ss, 24.13.
- 65 PKG 1978, N 3, 15; RJN 1980, 57, JdT 1984 I 444; un arrêt valaisan non publié du 7.12.77 a retenu une indemnité de CHF 20.– par jour pour les frais fixes d'un véhicule accidenté; RSJ 1981, 79 ss; KG ZH, ZR 96, 1997, 47 ss.
- 66 Cf. ROBERTO, N 24.06 ss.
- 67 Cf. TC, RJN 1980 57 (ég. In JdT 1984 I 444).
- 68 Cf. BK-BREHM, N 83; WERRO, note à l'arrêt du BGH du 7.5.96, REDP 1999 71 ss, 73.
- 69 Dans ce sens, cf. TC, RFJ 1999 229, c. 2b/cc/bbb.
- 70 ATF 126 III 388, c. 11a.
- 71 TF, 4A_282/2009, c. 3, SJ 2010 I 507.
- 72 Pour une analyse approfondie et convaincante, cf. TOLOU, N 154 ss.

- 73 Pour une illustration en matière d'immeuble, cf. [ATF 145 III 223](#); à ce sujet, cf. WERRO, RSJ 2020, 422; cf. ég. SIEGENTHALER, DC 2019 339 ss.
- 74 Cf. CHAPPUIS B., Dommages, 166 ss.
- 75 [ATF 115 II 474](#), c. 3, JdT 1990 I 216; l'Obergericht zurichois avait pour sa part admis la réparation: OGer, ZR 79/1980, N° 131, 284.
- 76 KassGer, ZR 96/1997, N° 16, 50.
- 77 CJCE, *Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG*, aff. C-168/00 du 12 mars 2002, Rec. 2002 I-2631. Pour une analyse de cet arrêt et de ses conséquences en droit suisse, cf. WERRO, Contrat de voyage, 699 ss; cf. ég. WERRO, RC, N 193 ss; ZINGG, *passim*.
- 78 Sur l'interprétation conforme à la jurisprudence de la CJUE des lois suisses qui constituent une reprise autonome du droit communautaire, cf. [ATF 137 III 226](#), c. 2.2; [ATF 136 III 552](#), c. 3.3; [ATF 133 III 180](#), c. 3.5, JdT 2010 I 239; [ATF 132 III 32](#), c. 4.1; [ATF 130 III 182](#), c. 5.5.1, JdT 2005 I 3; [ATF 129 III 335](#), c. 6, JdT 2003 II 75; cf. ég. WERRO, Tort moral, 18; *idem*, Contrat de voyage, 707 s. En application de l'arrêt *Leitner*, des tribunaux cantonaux ont accordé une indemnité pour vacances gâchées; cf. p.ex. CJ GE, arrêts ACJC/511/2004 du 23 avril 2004, ACJC/1198/2003 du 14 novembre 2003, ACJC/602/2005 du 13 mai 2005; à ce sujet, cf. CHAIX, 416 ss.
- 79 Cf. WERRO, RC, N 198 ss et 203 ss.
- 80 WERRO, Dommage, 17 s.; *idem*, Tort moral, 18. Pour une réparation en dehors du contrat, cf. *Ichard v. Frangoulis* [1977] 1 WLR 556 (accident de la circulation routière); en dehors d'un contrat conclu à forfait, cf. *Jarvis v. Swans Tours Ltd* [1972] EWCA Civ 8, [1973] 1 All ER 71.
- 81 Cf. House of Lords, *Ruxley Electronics and Construction Ltd v. Forsyth* [1995] 3 All ER 268, concernant l'indemnisation du propriétaire ayant reçu une piscine de la valeur marchande de celle qu'il avait commandée, mais qui n'avait pas la profondeur spécifiée dans le contrat; à ce sujet, cf. WERRO, Le coût excessif de la réfection de l'ouvrage et la sanction du contrat en cas de déplaisir consécutif au défaut, DC 2008 116 ss.
- 82 *Contra*: TF, 4C.169/1998.
- 83 CHAPPUIS B., Moment, N 133 ss; CHAPPUIS G., Préjudice, 282 ss; ROBERTO, N 29.31 ss.
- 84 [ATF 131 III 360](#), c. 8.1 et les réf. citées.
- 85 [ATF 132 III 321](#), c. 3.1, JdT 2006 I 447; TF, [4C.195/2001](#), c. 5; REY/WILDHABER, N 303 ss; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 8 N 79 s.
- 86 TF, [4A_259/2012](#), c. 3.1.2. Le lésé doit rendre vraisemblable qu'il se livrait effectivement à des travaux ménagers: TF, [4A_23/2010](#); de la même façon, le lésé ne peut pas se contenter d'évaluer de manière abstraite son dommage ménager en invoquant CO 42 II: TF, [4A_298/2012](#), c. 3.2; cf. ég. TF, [4A_500/2009](#), c. 3.1 (à propos d'un enfant).
- 87 [ATF 132 II 128](#), c. 4.1, RDAF 2007 II 22; [ATF 127 III 403](#), c. 4b, SJ 2001 I 605.
- 88 WERRO, RC, N 73; *idem*, Dommage ménager, 20.
- 89 Cf. WERRO, Dommage ménager, 28 et 36. Pour une critique de l'évaluation abstraite, cf. CHAPPUIS G., Le préjudice ménager: encore et toujours ou les errances du dommage normatif, REAS 2004 282 ss, 283 ss.
- 90 FELLMANN/KOTTMANN I, N 2029; LANDOLT, Pflegeschaden, 71.
- 91 TF, [4C.276/2001](#), c. 6b/bb; LANDOLT, REAS 2011, 4.
- 92 BK-BREHM, CO 46 N 15; FELLMANN/KOTTMANN I, N 2030.
- 93 [ATF 97 II 259](#); TF, [4A_500/2009](#), c. 2.1; TF, [4C.276/2001](#), c. 6b/aa.
- 94 TF, [4C.276/2001](#), c. 6b/bb; pour plus de détails, cf. LANDOLT, Pflegeschaden, 83 ss; ACHTARI, N 34 ss.
- 95 [ATF 132 III 379](#), c. 3.3.2.
- 96 [ATF 117 II 259](#), c. 3; CHAPPUIS B., Dommages, 173; cf. ég. ROBERTO, N 29.57 ss.
- 97 WIDMER/WESSNER, 94.

- 98 On parle de «*wrongful conception*» ou «*wrongful pregnancy cases*» en cas de naissance d'un enfant non désiré – en principe en bonne santé – consécutivement à une stérilisation manquée ou à un manque d'information du médecin sur les risques liés à la stérilisation, et de «*wrongful birth cases*» en cas de grossesse désirée, mais de naissance non désirée d'un enfant handicapé, consécutivement à une mauvaise information de la mère par le médecin quant aux risques liés à l'état de santé de l'enfant; dans les deux types d'actions, les parents agissent en réparation des frais d'entretien de l'enfant; cf. BRÜGGEMEIER/COLOMBI CIACCHI, 19 s.; cf. ég. MÜLLER, RC, N 111.
- 99 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 35; OFTINGER/STARK I, § 2 N 45 ss; ROBERTO, N 05.16 ss, 29.64 ss; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.04; sur l'ensemble de la question, cf. MANNSDORFER, N 323 ss.
- 100 Pour un aperçu de la question, cf. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.04; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 35.
- 101 ATF 132 III 359, JdT 2006 I 295 (violation du contrat médical). A noter qu'en cas de responsabilité extracontractuelle, le résultat ne saurait être différent; l'acte illicite consisterait alors dans une atteinte à la liberté personnelle; pour une approche fondée sur l'effet protecteur du contrat, cf. ég. STÖCKLI, 201 ss.
- 102 Cf. TORRIONE, 388 ss; d'un autre avis, CHAPPUIS G., Naissance d'un enfant non désiré, 378 ss.
- 103 ATF 132 III 359, c. 4.1, JdT 2006 I 295; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.04.
- 104 ATF 132 III 359, c. 4.3.2, JdT 2006 I 295; dans le même sens, TORRIONE, 394 ss.
- 105 ATF 132 III 359, c. 4.4.2, JdT 2006 I 295.
- 106 ATF 132 III 359, c. 4.8, JdT 2006 I 295; le TF n'a donc pas suivi la position de l'OGH autrichien, qui instaure un régime de responsabilité différencié selon que l'enfant naît sain ou handicapé (cf. OGH, arrêt du 25.05.1999, JBl/Vienne 121/1999, 593 ss).
- 107 On parle de «*wrongful life cases*» lorsque l'enfant handicapé agit en réparation du dommage et du tort moral subi; cf. BRÜGGEMEIER/COLOMBI CIACCHI, 21.
- 108 TF, 4A_551/2013, c. 9, SJ 2015 I 162; dans le même sens, cf. aussi l'arrêt de la 2^e Cour civile de la Cour suprême du canton de Berne, ZK 10 5969, du 2.5.2011 (pour une analyse approfondie, cf. MÜLLER, Wrongful-life, 47 ss).
- 109 Dans le même sens, cf. CHAPPUIS G., Naissance d'un enfant non désiré, 381; d'un autre avis, MANNSDORFER, N 1365 ss. Pour le droit à des prestations, mais contre le fait d'obtenir une indemnité au moyen d'une action civile, cf. MÜLLER, Wrongful-life, 49 ss.
- 110 A ce sujet, cf. TORRIONE, 391 et 395 ss et les réf. à d'autres opinions.
- 111 Cf. arrêt de la C. Cass. (F) 99-13.701 du 17.11.2000, in http://www.courdecassation.fr/publication_s_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/no_526_13_62/, qui a fait droit à la demande d'un handicapé dont la mère n'avait pas pu avorter à la suite d'une erreur de diagnostic; cf. ég. arrêt de la C. Cass. (F) 00-11.197 du 28.11.01, qui a accordé le bénéfice d'une indemnisation à un garçon né trisomique en 1995 pour le préjudice que lui a créé sa naissance. A ce sujet, cf. ég. CHAPPUIS G., Naissance d'un enfant non désiré, 378 ss; TORRIONE, 392 ss.
- 112 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dont l'art. 1 I dispose: «Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance». Cette loi a été abrogée en 2005 et incluse dans le Code de l'action sociale et des familles, dont l'art. L114-5 reprend la teneur de l'art. 1 I.
- 113 Dans ce sens, cf. AppGer., BJM 2000 306, c. 3; indemnisation en revanche accordée par le BzGer Arbon thurgovien: cf. BzGer. Arbon TG, SJZ 82/1986 46 ss. L'ATF 132 III 359 ne soumettait pas cette question à l'analyse du TF, mais l'arrêt mentionne que le TC valaisan a accordé une indemnité pour tort moral de CHF 5000.– aux parents.
- 114 Cf. TF, 4A_551/2013, SJ 2015 I 162, où le TF a confirmé la décision de l'instance cantonale qui avait accordé une indemnité pour tort moral de CHF 50 000 à la mère d'un enfant affecté d'une trisomie 21, après avoir retenu que le médecin avait violé son devoir d'information en n'informant pas la mère de la possibilité de faire des tests qui auraient pu permettre de diagnostiquer la trisomie.
- 115 Dans ce sens, cf. MANNSDORFER, N 946.
- 116 TF, 4A_551/2013, c. 9, SJ 2015 I 163; cf. ég. *Turpin v. Sortini*, Supreme Court of California, 1982, 31 Cal. 3d 220, 643 P. 2d 954, où on met l'accent sur la difficulté d'évaluer le tort moral comme un motif pour refuser l'indemnité.

- 117 Sur cette notion, cf. [ATF 142 IV 237](#), c. 1.5.1; [ATF 133 III 462](#), c. 4.4.2; WERRO, RC, N 219 ss.
- 118 [ATF 142 IV 237](#), c. 1.5.1; [ATF 133 III 462](#), c. 4.4.2; BK-BREHM, N 105 ss.
- 119 TF, [8C_307/2015](#), c. 3.2; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 50; PROBST, Causalité, 20 s.
- 120 PROBST, Causalité, 20 s.
- 121 A ce sujet, cf. PROBST, Causalité, 19 ss, qui souligne à juste titre que l'approche n'est pas seulement logique, mais qu'elle répond aussi aux besoins d'un bon fonctionnement des rapports sociaux; cf. ég. SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 21.04; REY/WILDHABER, N 715 ss; WERRO, RC, N 227 ss.
- 122 SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 21.04; [BSK-KESSLER](#), N 27.
- 123 [ATF 135 V 269](#), c. 5.3; BK-BREHM, N 149f; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 51.
- 124 PROBST, Causalité, 19; pour un exemple tiré de la jurisprudence du TF, cf. TF, [6B_549/2008](#).
- 125 BK-BREHM, N 149g; REY/WILDHABER, N 715 ss.
- 126 Cf. p.ex. TF, [4A_115/2014](#), c. 6.4.3; TF, [4A_275/2013](#), c. 6; FELLMANN/KOTTMANN, N 508.
- 127 [ATF 113 II 323](#), c. 5, JdT 1988 I 699; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 18.29.
- 128 [ATF 113 II 86](#), c. 3b, JdT 1987 I 442; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 21.05; OFTINGER/STARK I, § 6 N 11a.
- 129 REY/WILDHABER, N 707 et N 715; PROBST, Causalité, 26 ss.
- 130 WERRO, RC, N 235; ROBERTO, N 06.09.
- 131 TF, [4A_416/2013](#); [ATF 132 III 715](#), c. 2.3; [ATF 115 II 440](#), c. 5, JdT 1990 I 362; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 60; FELLMANN/KOTTMANN, N 488 s.
- 132 TF, [4A_350/2019](#); TF [4A_65/2019](#); cf. ég. [ATF 132 III 715](#), c. 2.3; [ATF 132 III 305](#), c. 3.4; PROBST, Causalité, 27; critiques, PETER/SAUERWEIN, Causalité et responsabilité des administrateurs, in Les causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, 2007, 145 ss, 164 s.
- 133 Cf. TF, [4A_350/2019](#); [ATF 131 III 115](#), c. 3.1, JdT 2005 I 279; TF, [2C_860/2008](#), c. 5, SJ 2010 I 449; TF, [4C_156/2005](#), c. 3.5.6, SJ 2006 I 221; [ATF 122 III 229](#), c. 5a/aa; WERRO, Comportement de substitution licite, 53 ss; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 64; BK-BREHM, N 149h.
- 134 WERRO, Comportement de substitution licite, 65 ss et 73.
- 135 WERRO, Comportement de substitution licite, 68 et 71 ss.
- 136 TF, [4A_350/2019](#); à ce sujet, WERRO, RSJ 2021, 598.
- 137 [ATF 115 II 440](#), JdT 1990 I 362. A ce sujet, cf. WERRO, Comportement de substitution licite, 67 s.
- 138 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 4 s.; KELLER I, 81; REY/WILDHABER, N 629; ROBERTO, N 06.36; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 19.02; FELLMANN/KOTTMANN, N 421.
- 139 [ATF 142 IV 237](#), c. 1.5.2; [ATF 139 V 176](#), c. 8.4.2; [ATF 129 II 312](#), c. 3.3; [ATF 119 Ib 334](#), c. 3c; ROBERTO, N 06.36 ss; REY/WILDHABER, N 665.
- 140 [ATF 142 IV 237](#), c. 1.5.2; [ATF 139 V 176](#), c. 8.4.3; [ATF 123 III 110](#), c. 2, JdT 1997 I 791; [ATF 116 II 519](#), c. 4a, JdT 1991 I 634.
- 141 KELLER I, 102; WERRO, RC, N 264.
- 142 TF, [4C_77/2001](#); WERRO, N 234; PROBST, Causalité, 28 ss.
- 143 TF, [5C_125/2003](#), c. 4.1, SJ 2004 I 407; [ATF 119 Ib 334](#), c. 5b; OFTINGER/STARK I, § 3 N 22.
- 144 [ATF 123 III 110](#), c. 3a, JdT 1997 I 791; PROBST, Causalité, 28 s; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 06.64.
- 145 Cf. [ATF 134 V 109](#), c. 8.1; [ATF 123 III 110](#), c. 3a, JdT 1997 I 791; cf. ég. TF, [4A_171/2012](#); TF, [4A_45/2009](#), c. 3.3.1, SJ 2010 I 73; FRÉSARD-FELLAY, N 613 ss, N 620; SCHAEER, 628 s.; d'un avis différent, récemment, ANGELOZZI, 218 s.
- 146 En matière d'accidents de type «coup du lapin», cf. [ATF 123 III 110](#), c. 3b, JdT 1997 I 791; [ATF 113 II 86](#), c. 1c, JdT 1987 I 442; cf. ég. KRAMER, Schleudertrauma: Das Kausalitätsproblem im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, BJM 2001 153 ss; HÜRZELER/TAMM/BIAGGI, N 326 ss, 344 ss.

- 147 FRÉSARD-FELLAY, N 613 ss; HÜRZELER/TAMM/BIAGGI, N 290; pour une critique, cf. BRULHART, 144, RUMO-JUNGO, N 157, WEBER/SCHAETZLE, 102 ss, GUYAZ, 121 ss, qui plaident pour une appréciation identique; cf. ég. PROBST, Causalité, 29, qui s'interroge sur l'opportunité d'une appréciation uniforme des fonctions remplies par les deux systèmes de compensation.
- 148 ATF 123 III 110, c. 3c, JdT 1997 I 791; REY/WILDHABER, N 640.
- 149 Cf. ATF 136 V 279; KAHIL-WOLFF, 18 ss.
- 150 Du même avis, avec des arguments pour et contre la distinction, cf. HÜRZELER, 87 ss; GÄCHTER, 40 ss; d'un autre avis, cf. FELLMANN/KOTTMANN, N 431.
- 151 Sur l'intérêt, cependant, de la victime à faire établir la causalité en droit social, cf. GUYAZ, 122.
- 152 Pour un aperçu des critiques, cf. PROBST, Causalité, 30; ROBERTO, N 06.54, 06.59 ss; FELLMANN/KOTTMANN, N 443 ss; cf., déjà, DESCHENAUX, 399 ss; cf. ég. ANGELOZZI, 211 ss.
- 153 Pour plus de détails, cf. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, N 2952 ss; ROBERTO, N 06.60 ss.
- 154 ATF 142 IV 237, c. 1.5.2; ATF 130 III 182, c. 5.4, JdT 2005 I 3; ATF 127 III 453, c. 5d; PROBST, Causalité, 30; BK-BREHM, N 136.
- 155 Sur le caractère trompeur du terme interruptif, cf. PROBST, Causalité, 21, qui souligne qu'en réalité, lorsque deux faits sont à l'origine d'un dommage, ils sont et ils en restent les causes; seule une appréciation normative conduit à la conclusion que, du point de vue de la responsabilité, on doit n'en retenir qu'une, plutôt que les deux.
- 156 TF, 4A_433/2013, c. 4.5.
- 157 ATF 102 Ib 257, c. 5.
- 158 MÜLLER, RC, N 221.
- 159 Cf. ATF 111 II 429, c. 1b (très mauvais temps); ATF 109 II 304, c. 5; REY/WILDHABER, N 692.
- 160 TF, 4A_433/2013, c. 4.5; DESCHENAUX/TERCIER, § 3 N 57; KELLER I, 95; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 20.02.
- 161 Cf. ATF 142 IV 237, c. 1.5.2; ATF 133 V 14, c. 10.2; ATF 130 III 182, c. 5.4, JdT 2005 I 3; ATF 116 II 519, c. 4b, JdT 1991 I 634; ég. TF, 4A_577/2015, c. 7.4; TF, 5C.213/2004, c. 5.
- 162 Pour d'autres exemples tirés de la jurisprudence, cf. BSK-KESSLER, N 21c.
- 163 WERRO, RC, N 275 et les réf. citées.
- 164 REY/WILDHABER, N 677; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 20.05.
- 165 ATF 105 II 209, c. 3. Pour une critique, cf. FELLMANN/KOTTMANN, N 464 et les réf. citées.
- 166 ATF 116 II 519, c. 4b, JdT 1991 I 634.
- 167 BK-BREHM, CO 43 N 81; DESCHENAUX/TERCIER, § 28 N 10; BSK-KESSLER, CO 43 N 19 s.
- 168 WERRO, RC, N 1737 ss; PERRITAZ, N 299 ss.
- 169 Pour un exemple dans lequel le TF a considéré la faute du tiers comme un facteur de réduction de l'indemnité, cf. ATF 59 II 37; cf. ég. PERRITAZ, N 321 ss.
- 170 ATF 130 III 321, c. 3.1; TF, 5A_406/2009, c. 4.1; KELLER I, 102.
- 171 DESCHENAUX/TERCIER, § 21 N 17.
- 172 WERRO, N 258 ss; WIDMER/WESSNER, 242 s.
- 173 ATF 132 III 715, c. 3.2, JdT 2009 I 183.
- 174 ATF 132 III 715, c. 3.1, JdT 2009 I 183; ATF 133 III 81, c. 4.2.2, JdT 2007 I 309; TF, 4A_262/2016, c. 4.4.2.1; CHK-MÜLLER, N 36.
- 175 ATF 133 III 153, c. 4.2.2; cf. ég. TF, 4A_38/2008 (manquement d'un avocat); pour une vraisemblance prépondérante en cas d'omission, cf. ATF 132 III 305, c. 3.5, JdT 2006 I 269; ATF 129 III 129, c. 8; TF, 5A_406/2009, c. 4 et réf. citées. Pour plus de détails, cf. BK-BREHM, N 117 ss et les réf. citées.
- 176 Pour une approche souple, favorable à la victime, cf. CJUE, aff. C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484; à ce sujet, WERRO, RC, N 582; *idem*, Annuaire, 280 ss; WERRO/CONSTANTIN, 178.
- 177 ATF 133 III 81, c. 4; cf. ég. WERRO, Le défaut du produit, ses catégories, sa preuve et les instructions du fabricant, RSJ 2008, 257 ss.

- 178 WIDMER/WESSNER, 244. Il en va de même dans CO 2020.
- 179 WERRO, RC, N 261; WIDMER/WESSNER, 244.
- 180 WERRO, RC, N 245; OFTINGER/STARK I, § 3 N 116 ss; PERRITAZ, N 280.
- 181 **ATF 113 IV 58**, JdT 1987 IV 138 (en matière pénale); pour un état de fait semblable, mais plus récent, cf. **ATF 143 IV 361** (en matière pénale), dans lequel le TF nie l'existence d'une faute commune entre les responsables; à noter qu'en matière civile la solution aurait sans doute été différente (à ce sujet, cf. PERRITAZ, PJA, 799).
- 182 WERRO, RC, N 248; MÜLLER, RC, N 842; PERRITAZ, PJA, 799.
- 183 **ATF 143 IV 361**; pour un résumé et une appréciation de la solution en matière civile, cf. PERRITAZ, PJA, 799.
- 184 En faveur d'une condamnation de tous les auteurs (potentiels) du préjudice, cf. FELLMANN/KOTTMANN, N 2754; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 67; WEBER, 121; en faveur d'une libération de tous les auteurs (potentiels) du préjudice, cf. BK-BREHM, N 145b; KELLER I, 103; PERRITAZ, N 286 s.; ROBERTO, N 06.34; en faveur d'une solution intermédiaire qui consacre un partage des responsabilités, cf. WERRO, RC, N 251; REY/WILDHABER, N 744.
- 185 WERRO, RC, N 251; REY/WILDHABER, N 744.
- 186 WERRO, RC, N 253; PROBST, Causalité, 22 s.; PERRITAZ, N 280.
- 187 REY/WILDHABER, N 733 s.
- 188 BK-BREHM, N 146; **BSK**-KESSLER, N 24; PERRITAZ, N 288 ss.
- 189 WERRO, RC, N 251; REY/WILDHABER, N 744.
- 190 WERRO, RC, N 251; REY/WILDHABER, N 744.
- 191 WIDMER/WESSNER, 245 et réf. citées.
- 192 WIDMER/WESSNER, 245 et réf. citées.
- 193 DESCHENAUX/TERCIER, § 7 N 24 ss; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 N 2.
- 194 OFTINGER/STARK I, § 5 N 63 ss; REY/WILDHABER, N 1003 ss; ROBERTO, N 07.04.
- 195 Cf. ROBERTO, N 07.06; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 N 18.
- 196 Cf. **ATF 114 II 376**, JdT 1988 I 688.
- 197 Cf. DESCHENAUX/TERCIER, § 7 N 27 s.
- 198 Cf. **ATF 90 II 9** (un écolier de douze ans dévissant à la main trois des quatre écrous du pylône d'une ligne à haute tension).
- 199 A ce sujet, cf. WERRO, Capacité, N 342; cf. ég. GAUCH, Der vernünftige Mensch, Ein Bild aus dem Obligationenrecht, in L'Image de l'homme en droit, Mélanges publiés par la Faculté de droit à l'occasion du centenaire de l'Université de Fribourg, 1990, 177 ss.
- 200 CO 2020-FELLMANN/MÜLLER/WERRO, 46 N 9 ss.
- 201 Cf. REY/WILDHABER, N 1011 ss et les réf. citées.
- 202 Cf. **ATF 130 III 193**, c. 2.2, JdT 2004 I 214; **ATF 130 III 571**, c. 4, JdT 2005 I 88; **ATF 126 III 113**, c. 2b.
- 203 Cf. WERRO, Capacité, N 297 ss.
- 204 SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 22.28.
- 205 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 N 19, parviennent à la même conclusion en affirmant que la faute de CO 97 ne vise que l'aspect subjectif de la faute, l'aspect objectif relevant de la violation du contrat et devant être prouvé par la victime.
- 206 A ce sujet, cf. WERRO, Capacité, N 252 ss.
- 207 Cf. WERRO, RC, N 1678 ss.
- 208 Cf. ég. FELLMANN, Der einfache Auftrag und die aktuelle Entwicklung im Recht der freien Berufe, in Il contratto di mandato nell'ordinamento giuridico, 2009, 19 ss.
- 209 TF, **4A_594/2017**; pour un commentaire de cet arrêt, cf. WERRO, RSJ 2019, 386 s.

- 210 DESCHENAU/STEINAUER, N 72 s.; **CR CC I-WERRO/SCHMIDLIN, CC 16 N 2 ss.**
- 211 REY/WILDHABER, N 991; WERRO, RC, N 307; **CR CC I-WERRO/SCHMIDLIN, CC 16 N 63 ss.**
- 212 Cf. **ATF 118 Ia 236**, c. 2b; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 N 8; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 22.06.
- 213 WERRO, RC, N 308; *idem*, Capacité, N 194; ROBERTO, N 07.32.
- 214 BK-BREHM, N 172 ss; DESCHENAU/STEINAUER, N 83 et les réf. citées.
- 215 Cf. TF, 4C.278/1999, c. 2, SJ 2001 I 110; cf. ég. **ATF 124 III 182**, c. 5; **ATF 116 II 422**, c. 4, JdT 1991 I 162; **ATF 111 II 89**, c. 2c; OFTINGER/STARK I, § 5 N 123 ss; **CR CC I-WERRO/ SCHMIDLIN, CC 16 N 59 ss**; pour plus de détails, cf. WERRO, Capacité, N 201 ss.
- 216 **ATF 123 III 306**, JdT 1998 I 27; **ATF 116 II 422**, JdT 1991 I 162; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 22.09; MÜLLER, RC, N 248.
- 217 Cf. pourtant **ATF 102 II 363**, JdT 1977 I 306; **ATF 90 II 9**.
- 218 Pour plus de détails, cf. WERRO, Capacité, N 262 ss et N 679 ss.
- 219 WERRO, RC, N 327; FELLMANN/KOTTMANN, N 567; ROBERTO, N 07.19.
- 220 **ATF 100 II 332**, c. 3; PERRITAZ, N 467 ss.
- 221 Cf. OFTINGER/STARK I, § 5 N 105; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 N 24.
- 222 Pour plus de détails, cf. WERRO, Capacité, N 438 ss; cf. ég. **ATF 100 II 332**, c. 3.
- 223 WERRO, Indemnité, 201 s.; PERRITAZ, N 479 s. D'un avis différent, WINIGER, Gravité de la faute, 15 ss.
- 224 **ATF 115 II 283**, c. 2; BK-BREHM, N 197.
- 225 WERRO, N 1195; ROBERTO, N 07.24.
- 226 **ATF 104 II 259**; DESCHENAU/TERCIER, § 7 N 42.
- 227 **ATF 100 II 332**, c. 3.
- 228 **ATF 112 II 128**, JdT 1986 I 142; KELLER I, 106; REY, N 669; WIDMER/WESSNER, 96 (réf. citées N 439) et 99; CHK-MÜLLER, N 19.
- 229 Cf. **ATF 132 II 305**, c. 4.1; TF, SJ 2000 I 549; **ATF 123 II 577**, c. 4; **ATF 119 II 127**, c. 3, JdT 1994 I 298; cf. BK-BREHM, N 33; REY/WILDHABER, N 797 et les réf. citées; CHK-MÜLLER, N 43.
- 230 **ATF 133 III 323**, c. 5.1; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.04; CHK-MÜLLER, N 43; dans une perspective historique, cf. WINIGER, 37 ss.
- 231 Cf. **ATF 132 III 122**, c. 4.1; **ATF 123 II 577**, c. 4; REY/WILDHABER, N 799 s.; **BSK-KESSLER, N 31**; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.04.
- 232 OFTINGER/STARK I, § 4 N 9; REY/WILDHABER, N 808 ss; **BSK-KESSLER, N 32**; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.04.
- 233 BK-BREHM, N 33g; MÜLLER, RC, N 160 s.; à ce sujet, cf. FELLMANN/KOTTMANN, N 283 ss.
- 234 Il en va différemment en droit français, où l'illicéité, comprise dans la faute, n'est pas une condition distincte de la responsabilité; cf. FABRE-MAGNAN, N 82 ss; GIOVANNONI, Note sur la responsabilité civile en cas de «dommage purement économique», RSA 1980 277 ss, 282.
- 235 **ATF 141 III 527**, c. 3.2.
- 236 Sur la notion de droit absolu, cf. **ATF 112 II 118**, c. 5e; GABRIEL, N 236 ss et réf. citées; cf. ég. SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.05; ROBERTO, N 05.07 ss; CHK-MÜLLER, N 44.
- 237 **ATF 118 Ib 473**, c. 2, JdT 1994 I 650; BK-BREHM, N 38; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 N 3 s.; OFTINGER/STARK II/1, § 16 N 43, 94 s.; **BSK-KESSLER, N 33**.
- 238 Cf. ROBERTO, N 05.02 et réf. citées. Le premier auteur qui a soutenu la conception objective de l'illicéité en Suisse est VON TUHR (cf. RDS 12 327).
- 239 Cf. TF, SJ 2001 I 525, c. 3; **ATF 125 III 86**, c. 3b, JdT 2001 I 73; **ATF 123 III 306**, c. 4a; BK-BREHM, N 38b; WINIGER, 58 ss.
- 240 Cf. **ATF 133 III 323**, c. 5.1; **ATF 116 Ia 169**, c. 2c, JdT 1992 IV 52; **ATF 90 II 274**, c. 4, JdT 1965 I 234; REY/WILDHABER, N 848 ss; ROBERTO, N 04.30 ss et 05.67.
- 241 Cf. **ATF 144 I 318**; MAGNIN/OVERNEY, 74 ss.

- 242 ATF 102 II 85.
- 243 ATF 129 IV 322, c. 2, commenté inCORBOZ/FLEURY, Blanchiment d'argent, REAS 2004, 218 ss. Selon le TF, l'élément subjectif de l'infraction doit toutefois aussi être réalisé, une violation «objective» de CP 305^{bis} n'étant en revanche pas suffisante: ATF 133 III 323, c. 5.2.3. Dans le même sens, cf. CHAPPUIS B., SJ 2000 II 304 ss et CORBOZ/FLEURY, REAS 2007, 258 ss.
- 244 Cf. ATF 126 II 63, c. 3a, concernant la LFE, dont le but est d'éradiquer, de combattre et de surveiller les épizooties.
- 245 ATF 141 III 527, c. 3.2.
- 246 Cf. ég. TERCIER, in Gedächtnisschrift Peter Jäggi, 1977, 239 ss.
- 247 BK-BREHM, N 35a; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 N 27; FELLMANN/KOTTMANN, N 301.
- 248 ATF 117 II 259, JdT 1992 I 559.
- 249 ATF 141 III 527, c. 3.5.
- 250 Cf. ATF 134 III 214, c. 2.1, JdT 2008 I 383.
- 251 ATF 134 III 529, c. 4.3, JdT 2009 I 42.
- 252 WERRO, RC, N 346; ROBERTO, N 04.116.
- 253 ATF 126 III 113, c. 2a/aa; ATF 115 II 15, c. 3, JdT 1989 I 595; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.29; BSK-KESSLER, N 37.
- 254 DESCHENAUX/TERCIER, § 21 N 17.
- 255 Cf. ATF 116 Ia 162, c. 2c, JdT 1992 IV 52; ATF 95 II 93, c. I/2, JdT 1970 I 330.
- 256 Cf. TF, SJ 2000 I 549, c. 2; ATF 126 III 113, c. 2 a/aa; ATF 123 III 306, c. 4b; ATF 121 III 358, c. 4a, JdT 1996 I 66; ATF 116 Ia 162, c. 2c, JdT 1992 IV 52; BK-BREHM, N 44; DESCHENAUX/TERCIER, § 6 N 46; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 N 32; OFTINGER/STARK II/1, § 16 N 26; REY/WILDHABER, N 899; BSK-KESSLER, N 38; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.32; FELLMANN/KOTTMANN, N 348.
- 257 ATF 66 II 114.
- 258 Cf. ATF 125 IV 9, c. 2a, JdT 2000 I 78; ATF 121 III 358, c. 4a, JdT 1996 I 66.
- 259 ATF 126 III 113; ATF 130 III 193, JdT 2004 I 214.
- 260 ATF 130 III 193, c. 2.3, JdT 2004 I 214; WERRO, DC 2005 185.
- 261 ATF 124 III 297, c. 5b, JdT 1999 I 268; ATF 119 II 127, c. 3, JdT 1994 I 298.
- 262 SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.33.
- 263 Cf. ATF 124 III 297, c. 5b, JdT 1999 I 268; WERRO, RC, N 353; *idem*, Sorgfaltspflichtsverletzung, 364 ss.
- 264 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 N 31 ss; BSK-KESSLER, N 38; CHK-MÜLLER, N 50; ROBERTO, N 04.89. Cf. ég. CHAPPUIS B./WERRO, 79 s., qui mettent en évidence que le devoir d'agir dépend de la situation juridique (définie par la loi, le contrat ou la création d'un risque; comp. CP 11) de celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé.
- 265 BK-BREHM, N 51c; WIDMER/WESSNER, 102; OFTINGER/STARK II/1, § 16 N 26 ss; CHK-MÜLLER, N 10 et 50; implicitement ég., WINIGER, 55 N 202.
- 266 REY/WILDHABER, N 902.
- 267 Le TF l'admet aussi; cf. ATF 124 III 297, c. 5b, JdT 1999 I 268; ATF 123 III 306, c. 4a.
- 268 Cf. p.ex. ATF 108 II 419, c. 5, JdT 1983 I 204; ég. ATF 121 III 350, c. 6c.
- 269 TF, 4C.409/2005, c. 3, SJ 2006 I 433; TF, 4C.247/2005, c. 3; TF, 4C.226/2002, c. 4.2; ATF 125 III 86, JdT 2001 I 73; ATF 92 II 328, JdT 1968 I 34.
- 270 TF, 4C.152/2001, c. 3a, SJ 2002 I 164.
- 271 Cf. ATF 116 II 695, c. 4, JdT 1991 I 625; ATF 111 II 471, c. 3, JdT 1986 I 485.
- 272 ATF 142 III 84, c. 3.3; TF, 4A_565/2012, c. 2.3; ATF 134 III 390, c. 4.3.2, JdT 2010 I 143; ATF 131 III 377, c. 3, JdT 2005 I 612; ATF 130 III 345, c. 2.1, JdT 2004 I 207.

- 273 Cf. WALTER, 147 ss; cf. ég. l'ensemble des contributions in CHAPPUIS C./WINIGER, La responsabilité fondée sur la confiance, 2001; LOSER, N 266 ss; pour une analyse critique de la doctrine et de la jurisprudence, cf. MORIN, Responsabilité fondée sur la confiance, 29 ss.
- 274 ATF 120 II 331, c. 5a, JdT 1995 I 359; TF, 4A_499/2007, c. 4.3.2, SJ 2008 I 361.
- 275 CHAPPUIS C., 21 ss.
- 276 ATF 120 II 331, c. 5a, JdT 1995 I 359; ATF 121 III 350, c. 6c; ATF 123 III 220, c. 4, SJ 1998 277; ATF 124 III 297, c. 6a, SJ 1998 460; TF, SJ 2000 I 549, c. 3a; ATF 130 III 345, c. 2.2, JdT 2004 I 207; ATF 133 III 449, JdT 2008 I 325; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 52.02; WESSNER, Responsabilité fondée sur la confiance, 55 ss.
- 277 ATF 120 II 331, c. 5a, JdT 1995 I 359.
- 278 ATF 133 III 449, JdT 2008 I 325; ATF 130 III 345, c. 2.2, JdT 2004 I 207.
- 279 ATF 130 III 345, JdT 2004 I 207: pas de responsabilité à la charge de l'architecte chargé d'évaluer la valeur d'un immeuble dans le contexte d'un prêt si le propriétaire utilise ultérieurement cette évaluation pour vendre l'immeuble; ATF 120 II 331, c. 5a, JdT 1995 I 359; ég. ATF 121 III 350, c. 6: responsabilité d'une association sportive qui, peu avant le début d'une compétition et sans raison valable, impose une épreuve de sélection supplémentaire à un athlète déjà qualifié selon les critères posés précédemment; à ce sujet, cf. BK-BREHM, N 53e; CHAPPUIS C., Responsabilité fondée sur la confiance, SJ 1997 165 ss.
- 280 TF, SJ 2000 I 549, c. 3a; WIDMER/WESSNER, 102 s. et réf. citées.
- 281 MORIN, 145 ss.
- 282 WERRO, RC, N 370 s.; BREHM, La responsabilité fondée sur la confiance dans le domaine des assurances, in La responsabilité fondée sur la confiance, Journée de la responsabilité civile 2000, 2001, 91 ss.
- 283 Cf. ATF 120 II 331, c. 5a, JdT 1995 I 359, dans lequel le TF a admis une responsabilité de Swissair en l'absence d'un fondement délictuel ou contractuel (*«bei Fehlen einer vertraglichen oder deliktischen Haftungsgrundlage»*); cf. ég. ATF 131 III 377, c. 3, JdT 2005 I 612; ATF 130 III 345, JdT 2004 I 207; WALTER, 147 ss; cf. ég. LOSER, N 1127 ss.
- 284 ATF 134 III 390, JdT 2010 I 143; pour un commentaire de cet arrêt, cf. LOSER, recht, 211 ss.
- 285 Cf. WERRO, RC, N 370 s.; *idem*, La responsabilité fondée sur la confiance: quelques variations sur un thème commun ou les leçons du droit comparé, in La responsabilité fondée sur la confiance, Journée de la responsabilité civile 2000, 2001, 109 ss.
- 286 WERRO, Sorgfaltspflichtenverletzung, 346 ss; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.04 et N 50.31; pour une analyse différente et le maintien de l'illicéité de résultat, cf. JAUN, 314 ss.
- 287 Cf. HONSELL, Haftpflicht, § 6 N 21; cf. ég. CHAPPUIS C., Distinction, 83 ss.
- 288 Cf. ATF 119 II 127, JdT 1994 I 298.
- 289 Dans le même sens, DESCHENAUX/TERCIER, § 2 N 24, qui justifient cependant leur point de vue avec le motif non décisif que l'activité à risque constitue un fait licite.
- 290 Cf. WESSNER, Droit contractuel et droit délictuel, 16 ss; pour une critique de l'AP RC sur ce point, cf. GAUCH, Vereinheitlichung, 315 s.
- 291 Cf. WERRO, RC, N 1678 ss.
- 292 ATF 130 III 193, JdT 2004 I 214, commenté in WERRO, DC 2005 185; ATF 126 III 113, commenté in WERRO, Quelques ruminations sur les relations entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle à partir d'un accident de télési, DC 2001 10.
- 293 ATF 133 III 121, c. 3.
- 294 CO 2020-FELLMANN/MÜLLER/WERRO, 46 N 4 ss.
- 295 WERRO, RC, N 1679; *idem*, Sorgfaltspflichtverletzung, 378.
- 296 WERRO, RC, N 387; FELLMANN/KOTTMANN, N 350; ROBERTO, N 04.118 ss.
- 297 Il faut distinguer ces motifs justificatifs des facteurs interruptifs du lien de causalité de LCR 59.
- 298 ATF 108 II 305, c. 2c, JdT 1983 I 609.
- 299 DESCHENAUX/TERCIER, § 6 N 50; CHK-MÜLLER, N 55.

- 300 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 7 N 4; **BSK-KESSLER, N 42**; FELLMANN/KOTTMANN, N 398.
- 301 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 7 N 7; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 51.04; d'un autre avis, BK-BREHM, N 243; FELLMANN/KOTTMANN, N 400.
- 302 BK-BREHM, N 235 ss.
- 303 **ATF 124 III 297**, c. 5e, JdT 1999 I 268.
- 304 DESCHENAUX/TERCIER, § 6 N 52; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 7 N 1 et 9.
- 305 **ATF 114 II 91**, c. 4a/aa, JdT 1988 I 310; pour d'autres exemples (essentiellement anciens) de jurisprudence, cf. BK-BREHM, N 246 ss.
- 306 **ATF 109 II 123**, JdT 1984 I 319.